



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

מס' תיק: 2/11

בפני המפקחת טלי להב

1
2

התובעים:

1. יונה שמיר
רבקה שמיר
 2. גדעון שחם
ורדה שחם
 3. עזריאל פופובסקי
מירי פופובסקי
 4. אלי יזרלביץ
דפנה יזרלביץ
- כולם ע"י ב"כ עו"ד יוסף שטרסלר
מרחוב הרב קוק 21, בני ברק

- נ ג ד -

3
4

הנתבעים:

1. שרה פריש
דניאל פריש
2. עודד איזנטל
אביבה איזנטל
3. ורגון שמואל
ורגון הדסה
4. צבי ליברמן
ברכה ליברמן
5. רינה כהן
שמואל כהן
6. אברהם ורטהיימר
אלינור ורטהיימר
7. דוד מלמד

יונה מלמד

8. אסתר הנר

אלימלך הנר

9. שמואל פרלמוטר

רחל פרלמוטר

01. עופר ישראל

דבורה ישראל

11. אחיקם וינשטוק

הילה וינשטוק

21. יצחק הלל סטופל

בת שבע סטופל

31. שלמה פנט

חנה פנט

41. שחר ישראל

51. אורלי צפריר

ערן צפריר

61. עמרני אברהם

עמרני רבקה

71. גולדנר חן

גולדנר מירב

81. שפרכר אהרן

שפרכר נורית

כולם מרח' הרב נריה 3 פתח תקוה

ע"י ב"כ עו"ד שרה פריש ו/או גיל זילבר

מרחוב משה דיין 14 פתח תקוה

1

פסק - דין

2

3

1. 4 הצדדים בעלי זכויות בדירות בבית משותף ברחוב הרב נריה 3 פתח תקווה, מקרקעין
- 5 הידועים כגוש 6715 חלקה 81 (להלן: "הבית"). התובענה הינה למתן סעד הצהרתי, לפיו
- 6 לתובעים זכות להרחיב את מרפסותיהם באופן זהה לזה המתוכנן ע"י יתר בעלי הזכויות.
- 7 וכן ליתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לבצע כל עבודות בנייה, מחוץ לשטח
- 8 דירתם. לחילופין וככל שתידחנה העתירות, מבוקש לחייב את הנתבעים בהפקדת ערבות
- 9 ביצוע נאותה שתבטיח ביצוע הבניה בהתאם להיתר הבנייה והימנעות מגרימת נזקים

לדירות התובעים ולרכוש המשותף. ולחילופין התבקש, כי ככל שתותר ההרחבה יפסקו	1
לתובעים תשלומי איזון, אשר יקבעו במינוי שמאי, לפי סעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין,	2
תשכ"ט-1969.	3
	4
2. טענות הצדדים:	5
	6
א. בא כוח התובעים טען בתמצית, כי התובעים זכאים אף הם להרחיב את מרפסות	7
דירותיהם, באופן זהה להרחבת המרפסות המתוכננת על ידי הנתבעים. לטענתו, ככל	8
שזכותם זו תפגע בקיומן של סוכות בעלי הדירות שמתחתן, הרי שאין זה מעניינם כיוון	9
שהרחבה זהה יכולה להיעשות על ידם "בלא להתחשב בסוכות שמתחתם". לטענתו,	10
הדיון בהיתכנות הרחבת דירות התובעים בפועל אינה רלוונטית משפטית ומכל מקום	11
גרסתם של הנתבעים אינה נכונה ואף אינה אמינה, שכן הנתבעים לא רצו כלל, בחוסר	12
תום לב, לבחון הצעות חלופיות. גרסתו של העד מטעמם האדריכל גולדווסר, נטען, אינה	13
עולה בקנה אחד עם עדותו בפני וועדת הערר בישיבתה מיום 29.6.10 והצעתם כרוכה אך	14
בתוספות עבודה צנועות בתשלום לא גבוה. התובעים אף זכאים למתן צו מניעה קבוע,	15
האוסר על ביצוע ההרחבה המתוכננת עד להשלמת 75% מההסכמות הנדרשות, אשר לא	16
תושלמנה בהעדר הסכמת התובעים ויתר בעלי הזכויות בקומות 6 ו-7. לדבריו, אין	17
מדובר אך בסתימת חללים, כי אם בהרחבת דירה במובנו של סעיף 71ב לחוק	18
המקרקעין, תשכ"ט-1969. בסיכומיו, טען להרחבת חזית בעצם העלאת הטענה, שיש	19
לראות בדיירי קומה 7 כמסכימים להרחבת מרפסות הנתבעים, בשל בניית חדרי הגג	20
בדירותיהם, וטען שאין זו "הרחבה" בהיותה בניה שבוצעה בשלב בניית הבית. טענה זו,	21
לגישתו, אף נעדרת תשתית עובדתית ויש להתעלם ממנה. בהקשרה של טענת השיהוי,	22
ציין כי אין בה כל ממש מאחר ותובענה זו הוגשה בשלב מוקדם ואף טרם קבלת היתר	23
בנייה. בסכומים שבו ועתרו התובעים לחילופין לחייב הנתבעים בהמצאת ערובה	24
להבטחת ביצוע העבודות בהתאם להיתר הבניה ובפסיקת תשלומי איזון לאחר מינוי	25
שמאי.	26
	27
ב. בכתב ההגנה נטען בתמצית, כי דין התביעה להדחות על הסף מחמת שיהוי, העדר תום	28
לב והעדר סמכות עניינית בהקשרן של העילות התכנוניות. לטענתם, במהלך שנת 2008	29
נודע לדיירי הבניין, כי ניתן תכנונית להשלים את החללים המצויים במרפסות וליצור	30
חפיפה אנכית בין כל המרפסות בבית. לפיכך, כינסו אסיפה כללית אליה זומנו כל דיירי	31
הבניין, לרבות התובעים. הדיירים כולם תמכו ברעיון והתקבלה הסכמה גורפת לכך.	32
לדבריהם, הוסכם מפורשות, כי כל הרחבה של המרפסות מותנית באי פגיעה במרפסות	33
הסוכה הקיימות בבניין. באותה אסיפה אף הוחלט לפנות לאדריכל דורון גולדווסר, על	34
מנת שיתכנן את הרחבת המרפסות ויפעל להשגת היתר בניה. הנתבעים חפצו בשיתופם	35

ובשילובם של התובעים בתכנית ההרחבה, כאשר אי הכללתם בתכנית נבעה מסיבות	1
אובייקטיביות ומקצועיות שהעלה אדר' גולדווסר. מנגד, נהגו לטענתם התובעים בחוסר	2
תום לב משווע ומרגע שנודע להם, כי לא יכללו בתכנית החליטו לטרפד אותה לחלוטין.	3
התנגדות שהגישו התובעים לוועדה המקומית לתכנון ובנייה נדחתה ובדיון בפני ועדת	4
הערר טענו, כי ניתן תכנונית לכלול גם אותם בתכנית ההרחבה. לתובעים הוקצה ע"י	5
ועדת הערר מועד להצגת תוכנית חלופית ומשלא עשו כן נדחה הערר. לטענתם, ביום	6
12.8.10 פנו התובעים אל הנתבעים במכתב, לפיו הם משלימים עם החלטת ועדת הערר.	7
ומתמקדים בדרישה לתשלומי איזון. הנתבעים סירבו להיעתר לבקשה מן הטעם שאין	8
בבניה המבוקשת פגיעה בזכויות הבניה היחסיות שלהם. לטענתם בשיהוי קיצוני של	9
חמישה וחצי חודשים לאחר החלטת ועדת הערר ולאחר משלוח המכתב על ידם הוגשה	10
התביעה דנן. לדידם דין התביעה להידחות על הסף מחמת חוסר תום לב שכן תמציתה	11
של התביעה מבוטא במימרה "גם לי גם לך לא יהיה". תוכניתם כוללת אך סגירת חללים	12
ברצפת מרפסותיהם והרחבה של מרפסות הקומות הראשונה והשנייה כך שיוצבו באותו	13
קו עם יתר מרפסות הבניין. כן ציין, כי רוכשי הדירות חובשי כיפה שהיו חלק מקבוצת	14
הרכישה להקמת הבניין, ולכן אין מקום לדיון במציאות בה תימנע הקמתה של סוכה	15
כשרה הקיימת כיום במרפסותיהם. לטענתם לנתבעים לא היה כל אינטרס להוציא את	16
התובעים מתכנית הרחבת המרפסות ואף האדריכל גולדווסר היה יוצא נשכר בתוספת	17
שכ"ט אילו נכללו בה ואולם, השתתפותם נמנעה משיקולים תכנוניים. "התכנית" שהגו	18
התובעים נטען לאו תכנית היא, באשר נוצרה היא מהבל פיהם בלבד מבלי שהוצג על ידם	19
עד היום בדל ראיה להיתכנותה וזאת על אף אינספור הזדמנויות לעשות כן. לטענתם	20
בהתאם להלכה הפסוקה, מקום שהתנגדות בעלי זכויות בבניין משותף להרחבת דירת	21
מגורים נגועה בחוסר תו"ל מוקנית למפקחת הסמכות לדחות את תביעתם, אף אם	22
המבקשים להרחיב את דירתם חסרים את הרוב הדרוש לכך בחוק המקרקעין. בידי	23
הנתבעים נטען 20 חתימות של דיירים, על גבי הבקשה להיתר הבניה, מתוך 28 דיירים	24
בבניין. 4 דיירי הקומה האחרונה, המודעים היטב לתכנית ההרחבה, לא הביעו כל	25
התנגדות לתכנית. בסכומיהם הועלתה הטענה, כי יש לראות בהם כמי שנתנו הסכמתם	26
להרחבה, כיוון שהרחיבו את חדרי הגג של דירותיהם. לטענתם אף במהלך הדיון הצהיר	27
מר פופובסקי, כי בהיעדר אפשרות לתכנית חלופית, הוא מסיר את התנגדותו. לדעתם	28
אין צורך בתשלומי איזון כיוון שהנתבעים אינם גורעים מזכויות הבניה היחסיות	29
המוקנות לתובעים. התובעים אף לא הוכיחו את זכאותם לתשלומי האיזון.	30
	31
ג. בסכומי התשובה של התובעים נטען, כי "הפוסל במומו הוא פוסל". לטענתם, כל	32
הטענות הלא נאות והבלתי נאותות המייחסות לתובעים העדר תום לב אינן	33
נכונות ונטולות יסוד. לטענתם, הוכח שהנתבעים סרבו כל העת לדון בהצעתם	34
החלופית של התובעים, ואף סרבו להיפגש איתם. האדריכל מטעמם מר	35

1	גולדווסר שיקר בפני ועדת הערר באומרו, כי לא נותרו קווי בניה לצורך מימוש
2	הצעתם החילונית של התובעים והנימוקים שהעלה בדיון כאן לא הועלו על ידו
3	בפני ועדת הערר. לדבריהם, אין תביעתם לוקה בשיהוי כלל כיוון שהתקופות
4	הקצרות הנקבעות ע"י הועדות מהוות אך ורק בגדר עיכוב קצר להוצאת ההיתר,
5	אך אין בהן משום הטלת מגבלות כלשהן או קציבת מועדים שלא נקבעו בחוק.
6	לטענתם, העד מר פופובסקי לא הסיר התנגדותו.
7	לדעתם, אין הבדל ממשי בשטח המרפסות של התובעים ושל הנתבעים, אלא
8	שאצל התובעים כמחצית שטח המרפסת הינה מרפסת סוכה. לטענתו פסיקת
9	הרוב קובעת, כי ככל שהתנגדותו של בעל דירה לעשיית שימוש ייחודי ע"י
10	אחרים ברכוש המשותף היא עניינית, אין המתנגד חייב לספק הסבר נוסף
11	להתנגדותו. כך הוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין האוסרת קבלת החלטת
12	הרחבה הפוגעת בסוכה של דייר חלה, רק במקרה בו הדייר הנפגע אינו נמנה על
13	יוזמי החלטת הרחבה ועל מבצעה. בכל מקרה, לנתבעים אין את הרוב הדרוש
14	לפי סעיף 71ב לחוק המקרקעין, ולכן יש לאסור עליהם את ביצוע ההרחבה.
15	סירובם בשלבים הראשונים מלשמוע כלל את הצעת התובעים מוכיחה לטענתם
16	כאלף עדים, כי שרירות לבם היא המניעה אותם.
17	עד כאן טענות הצדדים.
18	
19	3. <u>רקע:</u>
20	
21	א. עיון בנסח הרישום מעלה כי הבית דן טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים, על אף
22	שנראה כי הוא ראוי להירשם ככזה.
23	על בית כגון דא חל ממילא פרק ו'1 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: " החוק ")
24	בשינויים המחויבים על פי סעיף 77ב, לרבות הוראות התקנון המצוי, המצוי בתוספת
25	לחוק.
26	זכויותיהם של הצדדים רשומות ממילא בדמות הערות אזהרה.
27	
28	ב. התובעים הינם בעלי הזכויות ב-4 דירות הקומה השישית בבית האמור, שבו 7 קומות ו-
29	28 דירות. הנתבעים כולם בעלי הזכויות ב-20 הדירות שבקומות 5-1 בבניין.
30	
31	ג. התובענה שבפני מתייחסת לתוכנית "תוספת שטח מרפסות בקומות א'-ה'", בהתאם
32	לבקשה להיתר בניה מס' 20091039, גוש 6715 חלקה 81 מגרש 6, תיק בניין מס' 16117
33	(נספח ב' לכתב ההגנה). עפ"י הערות הבדיקה של מרכזת וועדת התכנון מיום 7.4.10,
34	מבוקש הגדלת מרפסות שמש בקומות א'-ה' בבנין בן 7 קומות ע"ע + סגירת חללים

קיימים בשטח כולל של - 323.24 מ"ר.	1
	2
ד. בדיון בהתנגדות שהוגשה ע"י התובעים החליטה וועדת המשנה לתכנון ובניה בישיבתה מיום 21.3.10 לאמור:	3
	4
"הבקשה הינה לסגירה של חללים קיימים. הוועדה סבורה כי סגירתם לא תשנה את חזית הבנין ולא תפגע בו. לאור האמור מחליטים לקבל ההתנגדות בחלקה ולאשר הבקשה בחלק היחסי של זכויות הבניה של המבקשים ושל מי שאינו מתנגד לבקשה בתנאי למילוי דרישות מה"ע. הוועדה אינה נכנסת ואין לה סמכות בטענות קנייניות בין הדיירים (תשלומי איזון)".	5
	6
	7
	8
	9
	10
ה. ערר שהוגש על ידי התובעים דכאן נדון בפני וועדת הערר, בישיבה מס' 08910 מיום 29.6.10, לפי החלטת הוועדה ניתנה לצדדים שהות של 7 ימים לנסות ולהגיע להבנה בנוגע להרחבת דירות הקומה ה-6. בהחלטתה מיום 26.7.10 נדחה הערר.	11
	12
	13
	14
	15
	16
ו. דיירי קומה 6 העבירו לידי הנתבעים מכתב, צורף כנספח ה' לסכומיהם, מיום 12.8.10 (להלן-"המכתב") לפיו קיבלו בצער את החלטת הוועדה המחוזית ובלשונם "לא נותר אלא לאחל למרחיבי המרפסות הנאה מהתוספות שיתווספו (ושלנו לא ניתנו) וינצלו התוספות לרווחתם מתוך אושר ובריאות". כן ציינו כי הם מבקשים "לממש את סעיף 71 ב' סעיף קטן ד' לתשלומי איזון". ביום 17.8.10 נשלח אליהם מכתבם של הנתבעים דכאן לפיו הם דוחים את דרישת התשלום ומכאן לטענתם התביעה.	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
4. <u>הסעדים:</u>	25
	26
בתובענה שבפני מנויים, איפוא, ארבעה סעדים, הראשון שבהם סעד הצהרתי לפיו לתובעים זכות להרחבת מרפסת דירתם באופן זהה לזה המבוקש ע"י הנתבעים.	27
	28
השני בקשה למתן סעד של מניעה האוסר על הנתבעים לבצע בניה מחוץ לתחומי דירותיהם, בעיקר בשל העדר רוב המתחייב לפי הוראת החוק.	29
	30
הסעדים השלישי והרביעי הינם סעדים חלופיים ולפיכך ידונו לאחר ההכרעה בסעדים הראשיים שהתבקשו. יוצא, איפוא, כי עיקרה של התביעה מכוונת למתן סעדים שבדיני היושר.	31
	32
	33
	34

1	
2	5. <u>תביעה למתן הסעד הצהרתי-</u>
3	
4	ככלל, בספרו של השופט א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי , מהדורה עשירית, עמ' 469 נאמר:
5	"הסעד ההצהרתי אינו סעד שגרתי והוא סעד מיוחד במינו. על כן, קבעה הפסיקה לגביו, כי
6	תביעה לסעד הצהרתי אינה נזקקת לעילת תביעה, במובנה המקובל. מאחר שפסק דין הצהרתי
7	ניתן לתובע כדי לשמור על זכותו מפני כפירה והכחשה בעתיד, הרי שתביעת הצהרה אינה
8	צריכה ביסוס של העילה כתביעת סעד מהותי".
9	
10	כך בע"א 656/79 מורי ס' גרינפלד נ' יעקב קירשן ואח', פ"ד לו(2), 309-
11	"מקורו של סעד הצהרתי הוא במשפט האנגלי, בבית המשפט של ה- CHANCERY ולא
12	בבתי המשפט, הדנים על-פי המשפט המקובל (ה- COMMON LAW) ראה ספרו של
13	ZAMIR, THE DECLARATORY JUDGMENT (LONDON), 1962. עם זאת, אין
14	רואים באנגליה את הסעד הזה כסעד שביושר במובן המקובל של המושג, אלא כסעד שהוא
15	SUI GENERIS, דהיינו, מתקיימים בו מרכיבי שיקול הדעת, המאפיינים את הסעד
16	שביושר, אם כי לא כל הכללים והמרכיבים האופייניים כל כך לסעד זה".
17	
18	ובה"פ (מרכז) 6091-06-08 יעקב כהן ואח' נ' קדרון מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ,
19	תק-מח 2009(2), 4316 -
20	"26. סעד ההצהרה מקורו בדיני היושר (ע"א 2140/01 נחמיאס נ' נכסי בני משפחת מושקוביץ
21	בע"מ, פ"ד נו(6) 481, 484 (2002); להלן: "פרשת נחמיאס"; ע"א 3182/02 אשד 1980
22	מהנדסים ויועצים תעשייה ניהול ומכון בע"מ נ' המגן חברה לביטוח בע"מ, ניתן ביום
23	25.12.03, פורסם במאגר נבו. להלן: "פרשת אשד"). בהיותו סעד מן היושר, אין בית המשפט
24	נזקק בהכרח לכל תביעה לסעד הצהרתי המובאת לפניו. הענקתו של סעד הצהרתי נתונה
25	לשיקול דעתו של בית המשפט, הרשאי לתת דעתו, בגדר שיקוליו, לכללים שנקלטו עם השנים
26	מעקרונות של יושר וצדק (רע"א 1910/04 אילונית פרויקטים תיירותיים בע"מ נ' בנק דיסקונט
27	לישראל בע"מ, פ"ד נח(6) 193, 198 (2004). להלן: "פרשת אילונית"; פרשת אשד; פרשת
28	גרינפלד). בית המשפט יירתע מלהעניק סעד הצהרתי לתובע, שהתנהגותו בנושא המשפט
29	לוקה בפגמים של שיהוי, חוסר תום לב והיעדר ניקיון כפיים (גורן, בעמ' 470). השיקולים
30	שביושר הינם מגוונים ואינם קופאים על שמריהם (פרשת נחמיאס). רשימת השיקולים
31	שביושר אינה רשימה סגורה (מ' קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי הלכה
32	ומעשה (כרך א', 2007)".
33	
34	התנאים להענקת סעד הצהרתי נמנו בפסק זה, לאמור-

29". תובע עשוי לזכות בסעד על דרך של הצהרה אם יוכיח את התקיימות שלושת התנאים	1
המצטברים הבאים:	2
האחד, כי קנויה לו זכות או כי התקיים מצב שעליו הוא מבקש להצהיר;	3
השני, כי מן הראוי לשריין אותה זכות - או אותו מצב - על ידי מתן פסק דין;	4
השלישי, כי לא קיימות נסיבות מיוחדות מכוחן אין להיעתר לבקשה (ראו ודוקו: פרשת	5
גרינפלד, בעמ' 316; ע"א 2447/93 מעיוף נ' אברהם, פ"ד מח(5) 206, 210 (1994); זוסמן,	6
בעמ' 556). לשון אחר: על התובע להראות כי נסיבות המקרה מחייבות כי הזכות לה הוא טוען	7
תיקבע דווקא בדרך של פסק דין הצהרתי (ע"א 291/56 שצופק נ' רפפורט, פ"ד יג 39 (1959)).	8
ור' גם ע"א 490/92 שאבי נ' אררט חב' לביטוח בע"מ פ"ד מ"ז(3) 700 (1993); ע"א 2447/93	9
מעיוף נ' אברהם פ"ד מ"ח(5) 206, "סדרי הדין האזרחי" מאת זוסמן (מהדורה תשיעית) 1994,	10
עמוד 488)".	11
	12
בפסיקה הנרחבת נקבעו התנאים בהם ימנע בית המשפט מלהעניק סעד הצהרתי, כאמור. בין	13
הנסיבות נמנה מקרה שבו מבוקש סעד הצהרתי על מנת להשיג חיוב כספי אופרטיבי (ר' ע"א	14
490/92 לעיל) ומקרה שבו השאלה המוצגת לפני בית המשפט היא אקדמית גרידא, או שמבקש	15
ההצהרה אינו יכול להצביע על עניין ממשי שיש לו בפתרון הבעיה המוצגת לפני בית המשפט, או	16
כאשר בידי תובע הסעד היכולת לתבוע סעד מהותי כדבר שבזכות ע"א 226/80 דר' א. כאהן ואח'	17
נגד מדינת ישראל, פ"ד לה(3) 463.	18
	19
ברע"א 84/98 צעד בריא-אלוש אורטופדיה בע"מ נ' sensograph, פורסם בנבו, כב' השופטת	20
שטרסברג-כהן, נקבע, כי -	21
"המדיניות הראויה הנקוטה בנושא של תביעות לפסק דין הצהרתי, אמורה להבטיח הליך	22
מהיר ויעיל שיסיים את הסכסוך בין הצדדים ולא פתיח למשפט נוסף לשם קבלת הסעד	23
האופרטיבי. ... אין לאפשר הגשת תביעות הצהרתיות חלקיות ללא חלק אופרטיבי כאשר סביר	24
להניח שבית המשפט יזדקק להליכים נוספים כדי ליישב את הסכסוך בין הצדדים". ראו גם:	25
פרשת מוזס; פרשת קשר בניין השרון; ע"א 4861/06, 4864/06 חברת ברום ים המלח בע"מ נ'	26
מגדל בניין חברה לביטוח בע"מ, ניתן ביום 28.4.09, פורסם במאגר נבו; ע"א 366/84 חלוץ נ'	27
מאגרי סחר מ.ס. בע"מ, פ"ד מ(1) 586, 588 (1986); ת"א (מחוזי-ת"א) 1154/07 ברנהולץ נ'	28
עזרא, ניתן ביום 12.11.07, פורסם במאגר נבו".	29
	30
וככלות הכל חזור ושנה נפסק-	31
"כידוע, סעד הצהרתי הנו סעד שביושר, וככזה מסור לשיקול-דעתו של בית-המשפט".	32
(ר' גם ה"פ (תל-אביב-יפו) 18124-05-11 - חברה ישראלית למובילים בע"מ ואח' נ'	33
אפקדו ציוד בע"מ ואח', תק-של 2011(4), 28156.	34
	35

1	א. <u>התנאי הראשון- האם זכאים התובעים לסעד ההצהרתי לו עתרו או בלשון</u>
2	<u>הפסיקה בחינת מילוי של התנאי הראשון, היינו, קיומה של זכות קנויה של</u>
3	<u>התובעים והאם התקיים מצב שעליו הם מבקשים להצהיר?</u>
4	
5	הסעד ההצהרתי הפוזיטיבי, כפי שנוסח בכתב התביעה והורחב ובואר בסכומי התובעים,
6	מכוון להצהרה על זכותם של התובעים להרחיב דירתם בעת בו מתוכננת הרחבת יתר
7	הדירות בבית. לשיטתם מדובר בזכות להרחבת דירותיהם "הרחבה זהה" ואף אם
8	הרחבה שכזו תפגע לחלוטין באפשרות להקים סוכה בדירות שמתחתם.
9	בלשון התובעים, יוזמתם של הנתבעים לבצע את הבנייה המתוכננת "מחייבת אותם
10	להסכים לכך שהתובעים יוכלו להרחיב באורח זהה, וזאת בלא שיוגבלו ע"י הסוכות של
11	התובעים". בהקשר זה הטעימו, כי הוראת סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-
12	1969, האוסרת קבלת החלטת הרחבה הפוגעת בסוכה של בעל דירה אחר בבית "מכוונת
13	למצב בו הדייר הנפגע אינו נמנה על יוזמי החלטת ההרחבה ועל אלה המבצעים אותה
14	ומרחיבים את דירתם שלהם מכוחה". ולכן, ככל שמבקשים הנתבעים להרחיב
15	דירותיהם הרי שהם מחויבים למצוא פתרון זהה לתובעים אף אם זה יבוא על חשבון
16	מרפסת הסוכה הקיימת היום בדירה. בהקשר זה הפנו לבחינת תוכניות חלופיות שלא
17	נבחנה לטענתם כלל על ידי הנתבעים.
18	
19	ומכאן אל בחינת הרישא לתנאי זה, כלומר על התובעים היה להוכיח כי קנויה
20	להם זכות בהקשר הנתבע. אודה, לא הונחה בפני כל תשתית ראיתית לכך.
21	למעשה הסתפקו התובעים, להוכחת טענותיהם, אך בתצהירו של תובע מס' 3 מר
22	פופובסקי. בעדותו ביקשו להתמודד עם טענות האדריכל גולדווסר ועם החלטות
23	וועדות התכנון באינסטנציות השונות. (אף לא הוכח, שהתובעים רכשו זכות
24	להיותם בעלי מרפסות בולטות הגדולות בשטחן מיתר המרפסות ממועד הרכישה
25	ועד בכלל).
26	
27	עיקר חולשתה של טענת התובעים מצויה דווקא בנסיבותיו של המקרה היינו
28	<u>בחינת התמלאות הסיפא לתנאי הראשון היינו- האם התקיים המצב שעליו הם</u>
29	<u>מבקשים להצהיר או האם ניתן להרחיב את מרפסות דירות התובעים.</u>
30	הן מעיון בתשריטים שצורפו והן מביקורי במקום במעמד הצדדים נוכחתי, כדלהלן:
31	הבית בנוי כיום בחזית מדורגת;
32	המרפסות הגדולות והבולטות שייכות לבעלי הדירות בקומות העליונות בהם התובעים;
33	בקומות הראשונה והשנייה אין כיום מרפסות הבולטות מקונטור הבית, ביתר קומות
34	הביניים בהם מתגוררים הנתבעים, מרפסות ששטחן קטן מאלה של המרפסות
35	העליונות;

1	טרם ההרחבה המבוקשת מצוידות כל הדירות בבית במרפסות סוכה, שנוצרו מחללים
2	מדורגים ברצפת המרפסות ;
3	בבנייה המתוכננת עתידים ממילא להיאטם חלק מן החללים הקיימים והמרפסות
4	תורחבנה למלוא שטח מרפסות הקומות העליונות בהן דירות התובעים ;
5	בשטח המורחב תיווצרנה מרפסות סוכה "חדשות" לדירות הנתבעים ;
6	בתום פרויקט הבניה המתוכנן יושלם קו בניין אחד הוא קו המרפסות של דירות הקומה
7	ה-6 וה-7.
8	
9	בפתח הדברים יוער, כי לאחר שעיינתי בתשריטים שצורפו וערכתי כאמור ביקור במקום
10	שוכנעתי, כי אכן כנטען ע"י הנתבעים אין התובעים מכוונים להרחבה פיסית זהה, שאינה
11	אפשרית כלל בהינתן המבנה הפיסי המדורג של הבית האמור. שכן, הרחבת המרפסות
12	המתוכננת תביא את כלל המרפסות בבית לקו הקונטור הקיים של המרפסות המצויות
13	בקומות העליונות. התובעים מכוונים כפי הנראה, <u>להרחבה אריתמטית זהה</u> , כלומר
14	תוספת שטח בשיעור המוסף ע"י הנתבעים.
15	
16	<u>ה"תוכנית חלופית"-</u>
17	
18	אין חולק, כי בתכנית שהוגשה לא נכללות דירות התובעים ודירות בעלי הזכויות
19	בקומה השביעית שחלקם אינם מבין מגישי תובענה זו. בשלב זה חלוקות הדעות.
20	הנתבעים טענו, כי עשו כל שלא ידם לצרף את התובעים ואת בעלי הזכויות
21	בקומה השביעית לתוכנית ואולם עמדתו המקצועית של האדריכל מנעה זאת.
22	התובעים טענו, כי הנתבעים מונעים מהם להשתתף בתוכנית וכי סירבו להידבר
23	עימם בדבר החלופות לתוכנית זו או ההיתכנות הכלכלית להרחבת מרפסות
24	דירותיהם. כל צד טוען בלהט להעדר תום לב של יריבו.
25	
26	התובעים לא תמכו את הטענה בדבר היתכנותה של תוכנית חלופית אף בבדל ראייה פרט
27	לעדויות של תובע 3 מר פופובסקי כאמור.
28	זאת ועוד, הן בהליך שבפני והן בדיון בפני וועדת הערר טרם מתן החלטתה התבקשו
29	הצדדים להגיש תוכנית חלופית שכזו, שבה יטלו, ממילא, חלק גם התובעים, תוכנית
30	שכזו כאז גם היום לא הוגשה ובהעדרה אף נדחה כאמור הערר. בהקשר זה, "...כלל
31	נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית
32	המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו,
33	ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה
34	מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר
35	משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר

1	וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה". (ר' ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 736,
2	760 ועל הלכה זו ע"א 2273/90 לימה בע"מ - פרל רוזנברג פד"י מז (2) 615,606).
3	
4	
5	זאת ועוד, אף שלטענת התובעים בסכומיהם אין להימצאותה של תוכנית זו כל
6	רלוונטיות לא ניתן להתעלם מכך שבהעדר תוכנית כאמור יתכן ומבוקש סעד
7	"אקדמי" בלבד שאינו אופרטיבי, דרישה למתן סעד שכזה צריכה להשתקלל בין
8	מכלול השקולים למתן הסעד האמור. ובהעדר ראיות מטעם התובעים יש לפנות
9	לראיות הנתבעים. ואכן, בדיון דכאן נשמעה עדותו של האדריכל ומגיש התוכנית
10	מר דורון גולדווסר, ממנה עולה כי הן בפרוטוקולים של הדיון בוועדות התכנון
11	והן בפני טען, כי בחן שיקולים ארכיטקטוניים שונים, לרבות הצורך להתחשב
12	בחזות הבניין ובמבנה הקונסטרוקטיבי של הבית על כל קומותיו ונוכח, כי לא
13	ניתן לשלב בהרחבה המתוכננת הרחבת מרפסות דירות הקומות השישית
14	והשביעית.
15	
16	בחקירתו הנגדית השיב, לאמור-
17	"ת. היתכנות של פרויקט מורכבת מאין סוף נתונים כשבאו אלי בתחילת הדרך הייתה
18	מטרה ליצור 28 מרפסות אני הייתי האיש הרע ואמרתי שלהערכתי המקצועית לא ניתן
19	להרוויח או לא כל הדיירים יכולים להרוויח את השינוי שחלו בתקנות ולכן לא ניתן
20	לממש את זה לכל הדיירים, אמרתי לאותו בחור תביאו אלטרנטיבה תכנונית בעיניים
21	שלי זה לא מעשי לא אסתטי לא עלויות רווח תועלת מקבלים מטר ומשהו ורוצים
22	לעשות קונזולות בשביל מטר ומשהו עשרות אלפי דולרים, זה לא הגיוני. יצטרכו עוד
23	בעלי מקצוע ויגלו שהעלות לא כדאית לא רוצים להגיע לזה, לא היתה תוכנית ממש
24	שכוללת את כל ההיבטים שהיו אמורים להיות כלולים בתוכנית אין לי בעד אף אחד או
25	נגד פופובסקי להיפך אני מרוויח מכל אחד שבונה הרבה כסף...
26	ש. מדובר על להבליט 8 מרפסות
27	ת. גם להבליט 80 ס"מ העלות מי שיבדוק אותה באופן מעשי אין סיכוי שהוא יעשה
28	אותה לפי ניסיוני המקצועי... אישורים בוועדות השונות ברגע שהבנין הזה חורג מעבר
29	לקווי הבנין כיום הוא מייצר חזית בעייתית מאוד ויכול לחרוג גם מעבר לקווי בנין ויכול
30	לעורר התנגדויות מה שעושים כרגע במסגרת הקונטור הקיים של הבנין
31	ש. נכון שקומה ראשונה ושניה לא במסגרת הקונטור
32	ת. השלמת צורה באותו קונטור...
33	ובחקירה חוזרת-
34	ש. הציג לך חברי צילום אתה העדת שמה שאמרו לך שאין היתכנות חברי אמר לך שאולי
35	זה כן יפה ואמרתי יכול להיות אבקש שתחדד את התשובה

1	ת. באופן תיאורטי הכל ניתן לעשות ניתן ליצר מרפסות חדשות ניתן לחפות את הבנין
2	בצורה חדשה ניתן לסגור את המרפסת סוכה של פופובסקי ניתן לעשות הכל אני מעריך
3	על פי ידיעותיי המקצועיות אחרי אלפי יחידות שתכננתי שאין התכנות מעשית הכוללת
4	בתוכה את כל המרכיבים
5	ש. לפני כן אמרת שלא יראה טוב מה זה יכול להיות
6	ת. ברור לחלוטין שבכל רגע נתון אפשר לעשות מהפכות בבנין שהבנין יראה טוב אני
7	חושב לאור מכלול השקלולים של עלויות ואסתטיקה אני חושב שלא ניתן יהיה לעשות
8	את זה".
9	
10	עדותו של תובע 3 מר פופובסקי לא שפכה אף היא לא שפכה אור שונה על עדותו של
11	האדריכל גולדווסר. בהקשר זה העיד לאמור-
12	"ש. יש לך תוכנית
13	ת. מה פרוש תוכנית הכנתי סקיצה מה אנחנו רוצים לא הלכנו ולקחנו אדריכל שיכין
14	תוכנית להגשה כי אני יודע שאנשים לא רוצים אם הם רוצים בוא נעצור את הדיון וניקח
15	בהסכמה.
16	ש. אני שואל אם יש תוכנית שהוגשה
17	ת. אני לא יכול להגיש תוכנית לדירה שלי שתסתום לאנשים את הסוכה אני לא יכול
18	להגיש תוכנית מקומה אחת עד חמישית...
19	"ש. האם הגשת איזה שהיא תוכנית שמתארת קווי בנין נספח בניה
20	ת. בגדול יש סקיצה למי להגיש
21	ש. כותבת לך ועדת הערר בהחלטה מ- 26/7/10 בה נדחתה התנגדות שלך נתנו לך 15 יום
22	בהם מעוכבת החלטת הוועדה ומאפשרים לך לפנות לערכאות מתאימות ככל שתמצא
23	לנכון, מפנה לנספח ב' לתצהיר של האדריכל גולדווסר- אומרת וועדת הערר שנותנים לך
24	עוד מועד להגיע להבנה האם במהלך המועדים האלה שבעה ימים + חמישה עשר ימים
25	הגשת איזה שהיא תוכנית למישהו כן או לא
26	ת. אמרנו נגיש תוכנית דיברתי עם צביקה נגיש כולנו לפי הקווים שלנו הם לא רצו
27	לשמוע. לא הגשתי תוכנית לעירייה.
28	ש. הגשת לוועדת הערר
29	ת. לא הם לא רוצים...
30	ש. במה תפגע אתה אם הבניה תעשה על פי מה שמבקשים בתוכנית
31	ת. אני לא אוכל להרחיב את הדירה שלי כמו שהם מרחיבים.
32	ש. מה נגרע ממך
33	ת. בתוכנית הזאת אני לא יכול לבנות לא אנחנו לא קומה שישית ושביעית...
34	"ש. זה נכון שבהליך זה אתה אמרת שאם תכנונית הדבר לא יהיה אפשרי תרד מהתביעה
35	ת. כן וישלמו לנו דמי איזון
36	ש. לגבי תשלומי איזון אנחנו נתווכח עקרונית אם אין אפשרות תכנונית אתה מוותר

1	ת. אני לא חותם אבל בגדול לא היתה לי התנגדות, אם מלכתחילה לא הייתי יכול לבנות
2	לא הייתי מתנגד שמעתי שאפשרי וועדת ערר אמרה שאפשרי
3	ש. למה לא הבאת חוות דעת של איש מקצוע
4	ת. לא היו מסכימים שרה אמרה לי בצורה הכי ברורה שפרלמוטר לא מוכן לצאת מטר
5	משם ניסיתי לשכנע אותו הוא לא הסכים אני אישית הייתי אומר שתבנו
6	ש. ניקח את הדירה של שרה פריש שהיינו בה, שרה פריש רוצה להביא את המרפסת לקו
7	הבנין ולסגור את החור שלידה זה לא יפגע בך כהוא זה נכון
8	ת. נניח
9	ש. מר ליברמן רוצה לסגור את החור שליד זה לא מפריע לך
10	ת. נניח
11	ש. הנתבעים האחרים רוצים לסגור את החור זה לא יפגע
12	ת. נניח" (ר' פרוטוקול דיון מיום 17.7.2011, עמ' 6, שורות 14-29).
13	
14	לא ניתן, איפוא, להתעלם מן העובדה שלא הוכח תכנונית כי ניתן להרחיב את
15	דירות התובעים, בשל המגבלה התכנונית בדמות חריגה אסורה מקו הבניין.
16	לטענת האדריכל גולדווסר כפי שהובעה בתצהירו ולא נסתרה-
17	"מעבר לעובדה, כי התובעים אינם מצרפים תכנית ערוכה ומקצועית שאליה
18	אני יכול להתייחס, הרי שהרעיון הכללי שהעלו, להבלטת המרפסות מעבר לקו
19	המרפסות הקיים, אינו ניתן לאישור במסגרת הוועדה המקומית (מדובר על
20	חריגה בשטחי המרפסות ובקווי הבניין). בנוסף, הדבר יפגע במראה הבניין
21	ובחזיתו האחידה ועלול לגרום לעלויות גבוהות. שנית ברצוני להעיר, כי גם ללא
22	תכנית הרחבת המרפסות דנן, אם היו דיירי הקומה השישית בלבד מבקשים
23	להרחיב את מרפסותיהם, לא ניתן היה לעשות כן מן הטעם שגם אז היו
24	נחסמות מרפסות קומות 4-5".
25	
26	מקובלת עלי, איפוא, עדותו של מר גולדווסר שלא נסתרה בראיות של ממש כי
27	רשויות התכנון לא תעתרנה לבקשה להרחבת מרפסות התובעים בהיותן חורגות
28	מקווי הבניין המותרים. אמנם ב"כ התובעים הכביר ביקורת על עמדתו של
29	האדריכל ואולם, בכל הכבוד, המוציא מחברו עליו הראיה הבא וטוען כי תתכן
30	בניה שכזו (נוכח החלטת וועדת הערר) בוודאי שעליו הראיה.
31	עתה, משהתברר שלא תיתכן הרחבה כמבוקשם של התובעים, בין מכלול השיקולים
32	למתן הסעד יש ליתן לכך משקל נוסף, שכן בהעדר התכנות לתוכנית של ממש לא הוכיחו
33	התובעים כי תצמח להם תועלת מקבלת הסעד. (ראו זוסמן, סדרי הדין האזרחי מה' 7
34	(בעריכת ש' לוי), ס' 454 עמ' 562; גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מה' 7 עמ' 388; ע"א
35	282/59 היועץ המשפטי נ' סימון, פ"ד יג 1387, 1388 (הנשיא אולשן); ע"א 539/78 לואל

נ' לויס, פ"ד לד(3) 281, 294.	1
	2
העדרה של היתכנות תכנונית או משלא התקיים מצב בו ניתן להרחיב את דירות	3
התובעים כמבוקשם, מכוון להוראת סעיף 71ב'(ד) לחוק המקרקעין, שכן	4
המחוקק צפה את הדינאמיקה שבחיי הבית המשותף ואת האפשרות שרק חלק	5
מדירות הבית תתרחבנה ברבות הימים.	6
בסעיף 71 ב' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן- "החוק") הדן בהרחבת	7
דירה, במסגרת תיקון 18 לחוק, נקבע לאמור-	8
"(ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת	9
להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה,	10
לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת	11
להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף.	12
(ה) לא הגיעו בעלי הדירות להסכמה באשר לגובה תשלומי האיזון, יקבעו התשלומים	13
על ידי שמאי מקרקעין, שימונה בהסכמה.	14
(ו) הוצאות השמאות יחולו על בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף,	15
לפני החלטת ההרחבה.	16
(ז) לא תתקבל החלטת הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות	17
סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה".	18
כלומר בס"ק ד' נקבע, כי יתכן גם יתכן מצב בו דירה מדירות הבית <u>אינה ניתנת</u>	19
<u>להרחבה</u> , כיתר הדירות.	20
ולכן, הנחת התובעים ומכוחה בקשתם למתן סעד <u>שבכל מקרה</u> הם זכאים להרחבת	21
דירתם אינה עולה בקנה אחד עם הוראות חוק המקרקעין.	22
	23
ב. <u>התנאי השני-</u>	24
משלא הוכח מילוי של התנאי הראשון אין להיזקק ממילא לתנאי השני המבקש	25
לבחון את הצורך לשיריון הזכות שלא הוכחה כאמור.	26
	27
ג. <u>התנאי השלישי-</u>	28
עפ"י התנאי השלישי יש לבחון האם קיימות נסיבות מיוחדות מכוחן אין להיעתר	29
לבקשה, דומה כי התשובה לכך חיובית.	30
בשים לב, לטענת התובעים לפיה הם מבקשים לקנות להם זכאות שכזו אף תוך	31
פגיעה מוחלטת בזכותם של יתר בעלי הדירות לבנות סוכה, שנהגו לעשות כן מאז	32
נבנה הבית. טענה משפטית זו הורחבה ע"י ב"כ התובעים בסיכומיו. לטענתו, ככל	33
שהנתבעים יזמו פרויקט הרחבת דירות בבית, יוזמה זו כשלעצמה מחייבת אותם	34
להכליל גם את התובעים בה והם מוחזקים כמסכימים להרחבת התובעים אף	35

1	אם הרחבה ספציפית זו תמנע מהם להקים סוכה מכאן ולהבא. בלשונו של ב"כ
2	התובעים בסכומיו-
3	"רצונך להמשיך ולבנות סוכה? אז אל תרחיב את דירתך. ואם בכל זאת הנך
4	מעוניין בשני הדברים גם להרחיב וגם להמשיך לבנות סוכה, נא התכבד
5	ובוא בדברים עם התובעים למצוא הפתרון שיניח דעת שניכם. וקיימים
6	פתרונות, אם קיים הרצון לפתור".
7	
8	ברם, בטענה זו מבקש ב"כ התובעים לקרוא בהוראות סעיף 71ב' (ז) לחוק
9	המקרקעין היפוך חזקות ונטלים. שכן הטענה כי הנתבעים כמי שיזמו את
10	הפרויקט מנועים מלעמוד על זכותם לבניית סוכה, לאחר ההרחבה המבוקשת
11	אינה עולה בקנה אחד עם פשט הכתוב בס"ק ז' כאמור. סעיף זו מכוון בפשוטו
12	למניעת אפשרות לביטולה של סוכה בשל הרחבת דירה ולא לזכות מוקנית
13	למניעת בניית סוכה על מנת לאפשר הרחבה, כמוצע ע"י ב"כ התובעים.
14	מדובר אמנם בהיפוך מילים אך כזה המביא לתוצאה הפוכה מזו המובעת
15	ברורות בלשון המחוקק ובוודאי חותרת תחת "ההגנה" שלשון החוק מבקשת
16	להעניק "למי שנהג לעשות כן לפני ההחלטה".
17	
18	זאת ועוד, בקשה לכפיית צירופם של התובעים לפרויקט הרחבה תוך מניעת
19	האפשרות לבנות סוכות תחתן, אף אינה עולה עם לשון סעיף 14 לחוק המקרקעין
20	ועם עיקרון תום הלב המחייב בוודאי מקום שמדובר במערכת יחסים בין בעלי
21	דירות-שותפים- בבית משותף. בהקשר של זה כבר נפסק-
22	"הן הרוב והן המיעוט חייבים לפעול בדרך מקובלת ובתום-לב (סעיפים 39 ו-61
23	לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973). המיעוט והרוב אינם זרים זה
24	לזה. עבותות של קניין מקשרים ביניהם. חוק המקרקעין מעניק לכל אחד מהם
25	כוחות כלפי רעהו. בהפעלת כוחות אלה יש לנהוג בהגינות" (ר' ע"א 810/82 זול
26	בו בע"מ נ' יהודית זיידה, פ"ד לז(4) 737, 740).
27	"כל זכות (במובן הרחב) המעוגנת בחוק המקרקעין צריכה להיות מופעלת בתום
28	לב; כל חיוב המעוגן בחוק המקרקעין צריך להתבצע בתום לב... תום הלב אינו
29	מניח "מידת חסידות" (ראו ע"א 148/77 רוט נ' ישופה, פ"ד לג 617 (1), 635).
30	תום הלב אינו דורש כי האחד לא יתחשב באינטרס העצמי שלו. בכך שונה
31	עקרון תום הלב מעקרון הנאמנות (החל על דירקטור, שלוח, אפוטרופוס או עובד
32	ציבור (ראו בג"ץ 164/97 קונטרס בע"מ נ' שר האוצר (טרם פורסם), וכן א'
33	ברק, שיקול דעת שיפוטי 1987 (473)). עקרון תום הלב קובע רמת התנהגות של
34	אנשים הדואגים, כל אחד לאינטרס שלו עצמו. עקרון תום הלב קובע, כי
35	השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות

מוצדקות ובהסתמכות ראוויה של הצד האחר. אדם לאדם - לא זאב, ולא מלאך;	1
אדם לאדם – אדם (רע"א 6339/97 משה רוקר נ' משה סלומון, תק-על 99(4), 1,	2
43 (1999).	3
החובה לנהוג בתום לב נלמדת אף מחובת תום הלב שבדיני החוזים-	4
"החובה לנהוג בתום לב בשימוש בזכות מעוגנת בסעיף 39 לחוק החוזים (חלק	5
כללי), תשל"ג-1973 (להלן - חוק החוזים). בין אם נראה את תקנון הבית	6
המשותף כהסכם... שאז חלה הוראת סעיף 39 הנ"ל בענייננו במישרין; ובין אם	7
נראה בתקנון פיקציה הסכמית, אשר חלה מכוח החוק ואינה יונקת את כוחה	8
מהסכמתם של בעלי הדירות, לא יהיה בכך כדי לשלול את תחולת סעיף 39	9
בסיטואציה שלפנינו... לקביעה זו משנה תוקף, כאשר מדובר ביחסי הגומלין	10
בין השוכנים בצל קורתו של בית משותף. יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל,	11
בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה	12
באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות עשויים יחסים אלו	13
להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקירבה פיסית הדוקה	14
בין הצדדים... המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של	15
האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור כי אם, ורק אם, יפעלו	16
בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית	17
המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו" (ע"א	18
2896/90 יוסף טרופקי נ' אלפונסו דיין, פ"ד מו(5) 454, 459-460).	19
	20
דרישת התובעים כאמור בשים לכך שהן הם והן שכניהם שומרי תורה ומצוות	21
אינה עולה בקנה אחד עם עקרון תום הלב המתואר.	22
	23
ד. אחרונה, בהקשר זה, טענת התובעים לקיומה של חזקת ההסכמה כפי שזו	24
מוצאת ביטויה בס' 71ב' (ג) לחוק המקרקעין. ואולם, בהעדר תוכנית קונקרטית	25
המבהירה מהי אותה הרחבה מבוקשת מצויים אין אנו עובדתית בנסיבותיו של	26
ס"ק ג', כיוון שדווקא הנתבעים מבקשים "להצטרף" לקונטור הבניה הנרחב של	27
התובעים, אמנם לא כזה שבוצע כהרחבה (וממילא, אין בו הסכמה	28
קונסטרוקטיבית) ואולם אף לא כזה שהוכח שהתובעים זכאים לשימורו בכל ימי	29
חיי הבית.	30
	31
ה. מכל האמור עולה, כי התובעים לא הוכיחו, איפוא, כי קנויה להם זכות בנסיבות	32
המקרה ואין ממילא להיזקק לשאלה האם ראוויה אותה זכות לשריון. לא הוכח	33
אף כי בכפיית צירופם של התובעים <u>לתוכנית שאינה קיימת כלל</u> תצמח להם	34
תועלת כלשהיא ודוק, תוכניתם של הנתבעים מצויה כאמור בפני שלבים סופיים	35

למתן היתר הבניה ולאחר שאלה הוציאו הוצאות ניכרות והתייגעו בהליכי התכנון השונים.	1
לא הוכח, כי מאזן הנוחות בתביעתם למתן סעד פוזיטיבי נוטה לטובתם, מכל הטעמים האמורים ובעיקר לאור העובדה שלא טרחו כאמור להציג באף אחד מן השלבים המייגעים בו נתונים התובעים תוכנית בניה אופרטיבית הן תכנונית והן כלכלית והסתפקו, על אף נטל הראיה, בהפרחת טענה בעלמא, כי ניתן גם ניתן לאפשר להם להרחיב את מרפסות דירותיהם הנמצאות ברום הבניה ובקווי הבניין התכנוניים המקסימאליים.	2
הבקשה למתן הסעד הצהרתי המבוקש נדחית איפוא.	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
6. בקשה למתן צו מניעה:	11
	12
אודה, לב ליבה של התביעה בפני וההתלבטות המשפטית מצויה דווקא בפתחו של הסעד השני הנתבע הוא בקשת התובעים ליתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לבצע כל עבודות בנייה, מחוץ לשטח דירתם.	13
	14
	15
התובעים נימקו בקשתם בכך שהחתומים על הבקשה למתן היתר בניה אינם מהווים 3/4 מבעלי הדירות "כל עוד לא יצטרפו אליהם דיירי הקומות השישית והשביעית".	16
	17
	18
	19
א. התנאי המקדמי או דרישת הרוב עפ"י חוק:	20
	21
אכן היטיבו התובעים לערוך חישוב אריתמטי פשוט ולגלות שבלא הסכמתם והסכמת בעלי דירות בקומה השביעית שמעליהם (כולם בעלי מרפסות מורחבות למלוא השטח) לא יעלה בידי הנתבעים להשיג ההסכמה המחויבת לפי לשונו של סעיף 71ב'(א) לחוק המקרקעין.	22
	23
	24
	25
בדיוק רב חסרים הנתבעים קול נוסף אחד בבית על מנת לצלוח את ההסכמה המחויבת בלשון הסעיף האמור.	26
	27
	28
בכתב התביעה טענו התובעים בהקשרו של צו המניעה המבוקש בלאקוניות "בהעדר רוב של 3/4 ממספר הדירות התומכות בפרויקט אין זה מזכותם של הנתבעים לבצע עבודות בניה כלשהן בבנין בהיותן כרוכות בפגיעה בזכות הקנין של התובעים"	29
	30
	31
הא ותו לא.	32
לאחר ששמעתי ועיינתי בתצהירו הבודד של עד התובעים הוא תובע 3 בעצמו, קראתי שוב ושוב את סיכומי התובעים ואת סיכומי התשובה לא מצאתי אלא את הטענה כי עצם הרחבת המרפסות או אף איטום החללים במרפסות הקיימות בהעדר אפילו קול	33
	34
	35

1	בודד אחד מן הדרוש עפ"י לשון החוק, הוא הוא פגיעה מהותית ובלשון בא כוחם-
2	"התנגדותם של התובעים מתאפיינת בהחלט בתום לב, יושר והגינות. התובעים בסך
3	הכל מבקשים ליהנות מהרחבה זהה להרחבה של הנתבעים. מה כאן אינו בתום לב?".
4	ושוב הא ותו לא.
5	
6	מכאן ולאחר סקירת הפסיקה הרלוונטית מצויים בפני שני פסקי הדין רלוונטיים
7	מנחים של בתי המשפט המחוזיים בתל אביב, והחלטה בבר"ע על אותו פסק הדין
8	בבית המשפט העליון, ופסק הדין של ביהמ"ש בחיפה. בעשא (חי') 09-04-13877
9	אילן קיסרי נ' שאחב שלומוב, פורסם בנבו (להלן-"עניין קיסרי"). שם נדונה
10	סוגיה דומה עד מאוד, <u>השאלה מה הדין כאשר למבקש להרחיב דירתו בבית</u>
11	<u>המשותף או לבצע שינוי שיש בו משום פגיעה ברכוש המשותף, אין את הרוב</u>
12	<u>הדרוש ע"פ סעיף 71 לחוק המקרקעין? וביתר שאת כיצד והאם על המפקח על</u>
13	<u>רישום המקרקעין בדונו בתביעה שכזו לבחון את נימוקי המתנגדים לבנייה</u>
14	<u>ברכוש המשותף, ואת תום ליבם של הצדדים בהקשר זה.</u>
15	
16	פסה"ד זה מאזכר מיניה וביה את ע"א 835/08 נטלה צבי נגד עטרה פרי ואח', פורסם
17	בנבו, שניתן בערעור אף הוא על החלטת כב' המפקחת על רישום המקרקעין בחיפה גב'
18	ציפורה פיגנבוויים, מספר שנים קודם לכן. שם למעשה קבע כב' השופט זרנקין שבגדר
19	סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להידרש גם לשאלה האם ההתנגדות להרחבת
20	הדירה נעשתה בתום לב, "והאם לא נתקיימו נסיבות בהן מן הראוי לכפות על
21	המתנגדים את הסכמתם הר כגיגית" עפ"י עקרון תום הלב שהותווה בין היתר ברע"א
22	6339/97 רוקר נגד סלומון פ"ד נ"ה (1) 199.
23	
24	בהקשר זה אף סבר, כי יש להחזיר את הדין למפקחת על מנת שזו תשמע את
25	טענות המתנגדים וטעמיהם ותכריע בבקשה לצו מניעה לפי טיבן של טענות
26	אלה. כב' השופט כהן סבר שבדין דחתה המפקחת את הבקשה לצו מניעה קבוע
27	וכי נימוקי ההתנגדות ענייניים בנסיבות המקרה ויש ליתן להם משקל כיוון
28	שעסקין בשמירת חזותו המיוחדת של הבניין ובאפשרויות ניצול הרכוש
29	המשותף לצורך חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה לפי תמ"א 38.
30	
31	ס. הנשיאה כב' השופטת וסרקרוג פסקה, כי היא מבקשת "להצטרף לפסק דינו
32	של חברי כבוד השופט זרנקין ולקבוע כי למפקחת נתונה הסמכות לדון בנימוקי
33	ההתנגדות ואף חובתה לעשותה כן. כשם שנתונה למפקחת הסמכות לבחון את
34	הפגיעה בזכותו המהותית של המיעוט ואף לבטל כליל את החלטת הרוב, כך
35	נתונה הסמכות לעשות כן כאשר מדובר בהתנגדות הרוב ועליה לבדוק את

1	נימוקי ההתנגדות. כל זאת גם אם הבדיקה הנדרשת תיעשה בזירות ותבחן
2	אם אכן מדובר בהתנגדות סתמית, שאינה עניינית (בהבדל מהתנגדות בלתי
3	סבירה לפי סעיף 59ג(ד) לחוק), כדוגמת התנגדות אשר יש בה כדי להצביע
4	לכאורה, על שימוש לרעה במימוש זכות הקניין או שמא מדובר בהתנגדות
5	ממניעים ענייניים. כך למשל, אם ההתנגדות של הרוב "המאורגן", או רוב
6	הנתון בידי אדם אחד, בהיותו הבעלים של מספר דירות בבניין, נעשתה מכוח
7	כוונת קנטור או בשל מוצא או מסיבות אחרות שנוגדות את עקרונות שיטת
8	המשפט, ואשר אין להם דבר או חצי דבר, עם הפגיעה בזכות הקניינית
9	לכשעצמה, לא יהיה מקום לאשר את ההתנגדות. סמכות כזו נתונה מכוח סעיף
10	14 לחוק המקרקעין, ועולה בקנה אחד עם העקרונות הבסיסיים של תום לב
11	בשיטת המשפט. ההתנגדות, כפי שהזכיר חברי השופט זרנקין תוך הפנייה
12	לפס"ד רוקר (רע"א 6339/97, פ"ד נה(1) 199) צריכה להיות הוגנת ותוך
13	התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר...בענייננו,
14	התייחסתי למונח התנגדות סתמית שעניינה כאמור, התנגדות בלתי הוגנת,
15	בלתי ראויה ואשר יש בה כדי לפגוע בעקרונות יסוד של השיטה, התנגדות
16	שאינה נוגעת למעשה לפגיעה בזכות הקניין ככזו, עד כדי שימוש לרעה באותה
17	זכות".
18	
19	בפרשת קיסרי יישמה ערכאת הערעור את העקרונות שהונחו בעניין נטלה הלכה
20	למעשה תוך ניתוח הכללים לבחינת התנגדות המיעוט להרחבת דירה בהעדר
21	מלוא הרוב הנדרש.
22	ודוק, הן בעניין נטלה והן בעניין קיסרי עמדה בפני המפקחת תשתית ראייתית
23	וטענה ברורה של התובעים לפגיעה מהותית בזכויותיהם כקבוע בסעיף 71 ג'
24	לחוק המקרקעין, לפיו-
25	"(א) בעל דירה המתנגד להחלטה שנתקבלה כאמור בסעיף 71ב(א), וטוען
26	לפגיעה מהותית בזכויותיו, בעל דירה המבקש מינוי שמאי מקרקעין בהעדר
27	הסכמה, או בעל דירה החולק על קביעת השמאי רשאי לפנות למפקח
28	בתביעה".
29	כפי שיוטעם להלן אין כן במקרה שבפני.
30	
31	בפרשת קיסרי עוד נקבע, לאמור-
32	"על כך גם יש להוסיף את תחולת עקרון תום הלב כפי שנקבע ב-רע"א 6339/97
33	רוקר נגד סלומון, פ"ד נ"ה (1) 199 (שהדיון בו התקיים בהרכב של 7 שופטי בית
34	המשפט העליון).

1	בנוסף לדברים שכבר הובאו לעיל במסגרת פסק דינו של כב' השופט ע. זרנקין ב-ע"א
2	(מחוזי חיפה) 835/08, אוסיף ואביא גם מדבריו של כב' הנשיא (בדימוס) א' ברק, בפסק
3	הדין רוקר נגד סלומון, שם, בעמ' 277 :
4	"השימוש בזכויות על-פי חוק המקרקעין צריך להיעשות מתוך הגינות. מושג תום-הלב
5	בהקשר זה משמעו אמת-מידה אובייקטיבית. לשם פגיעה בעקרון תום-הלב, אין נדרש
6	כי בעל הזכות יפעל מתוך זדון או רוע-לב. די בכך שפעולתו אינה עולה בקנה אחד עם
7	<u>"הסטנדרדים הערכיים הראויים של החברה הישראלית, כפי שבית המשפט מבין</u>
8	<u>אותם מעת לעת"</u> ...") (ההדגשה שלי – י.ג.)
9	ובהמשכו של אותו עמוד :
10	"תום-הלב חל על כל שימוש בזכות, בין שימוש בזכות הקניין הגורם נזק לזולת, ובין
11	שימוש בזכות הקניין שנועד להגן על זכות הקניין (או זכות אחרת) מפני מתנכלים לה."
12	וכן :
13	"לשופט נתון שיקול-דעת - בגדרי המרחב הניתן לו מכוח פעולתו של עקרון תום-הלב -
14	בהענקת סעדים הפוגעים בזכויות על-פי חוק המקרקעין (ראו ע"א 782/70 הנ"ל [6]).
15	היקפו של שיקול-דעת זה נגזר מעוצמת פעולתו של עקרון תום-הלב". (שם, עמ' 277,
16	סיפא – עמ' 278 רישא).
17	עוד כתב כב' הנשיא (בדימוס) א' ברק, שם, בעמ' 278 :
18	"זכות הקניין ככל זכות האחרת אינה מוחלטת. כל הזכויות כולן הן יחסיות. זכות
19	הקניין אינה הזכות לנהוג שלא בתום-לב. על-כן נתון תמיד שיקול-דעת שיפוטי -
20	בגדרי עקרון תום-הלב - בהענקת סעדים בגין פגיעה בזכות הקניינית... מהותה של
21	הזכות משפיעה על היקף פעולתו של עקרון תום-הלב בגדריה. כל זכות והערכים
22	והאינטרסים המוגנים על-ידיה ; כל זכות ועוצמתה שלה ; כל זכות ואיזוניה שלה
23	ביחסה עם ערכים ואינטרסים נוגדים ; כל זכות ומידת השפעתו של תום-הלב עליה."
24	וכן, שם, בעמ' 279 :
25	"עקרון תום-הלב קובע את אופן התנהגותם של אנשים שמציאות החיים הפגישה
26	ביניהם. הוא קובע כי התנהגות זו צריכה להיות ביושר ומתוך הגינות כנדרש על-פי
27	תחושת הצדק של החברה בישראל. מעצם מהותו, עקרון תום-הלב מהווה אמת-מידה
28	"פתוחה" המשקפת את תפיסות היסוד של החברה הישראלית באשר להתנהגות
29	ראויה בין בני-אדם. הקטגוריות של תום-לב לעולם אינן סגורות ; לעולם אינן נוקשות
30	ולעולם אינן שוקטות על השמרים. תום-הלב מכניס לשיטתנו יסוד של גמישות
31	המאפשר לשיטה להתאים את עצמה לצורכי החיים המשתנים. הוא מאפשר למשפט
32	לגשר על הפער בין צרכיו של הפרט לצרכיו של הכלל..."
33	ס"ב. כשאני מציב לנגד עיניי את הוראות החוק והפסיקה מחד גיסא, ואת קביעותיה
34	העובדתיות של כב' המפקחת בפסק דינה והתרשמויותיה מביקוריה בבית המשותף
35	מאידך גיסא, סבורני שבעיקרו של דבר, ולמעט בשלוש סוגיות אותן אפרט להלן, אין

מקום להתערבותנו בפסק דינה של כב' המפקחת שהכריעה את הדין כראוי בנסיבות	1
הספציפיות שהיו מונחות בפניה כשמחד גיסא, מחזיקות המשיבות במחצית בלבד מן	2
הדירות שבבנין ולכן אין להן שיעור הבעלות הנדרש לצורך תחולת ההוראה שבסעיף 71	3
בי'(א) של חוק המקרקעין, אך מאידך גיסא, יש לבחון את נימוקי ההתנגדות של	4
המערער, והאם עולים הם בקנה אחד עם עקרון תום הלב, כמפורט כבר לעיל". (ר'	5
פסה"ד בעניין קיסרי, בעמ' 31-29).	6
	7
זאת ועוד, בפסק הדין שניתן לא מכבר ע"י כב' השופט שנלר בעש"א (מח')	8
45019-07-10 רסלר נ' תירוש ואח' , פורסם בנבו, נדון ערעור על החלטת כב'	9
המפקחת גב' מירה אראלי בתל אביב לפיו נדחתה על ידה בקשה למתן צו מניעה	10
קבוע האוסר על בניית מעלית- אף בהעדר הרוב החוקי הנדרש - מן הטעם	11
שהמבקש לא הוכיח את טענתו לפיה בניית המעלית תפגע בגישה ליחידות	12
שבבעלותו בבית המשותף. כב' המפקחת דנה בתחולת עקרון תום הלב בנסיבותיו	13
של המקרה, לרבות בחינת הבניה מושא ההתנגדות שבוצעה על ידי המתנגד שלא	14
עפ"י היתר תכנוני.	15
	16
כב' השופט שנלר בפסיקתו בעניין רסלר פסק לאמור :	17
"מבחינת המסגרת הנורמטיבית, לכאורה המחוקק אמר דבר בקובעו את התנאי	18
המקדמי הנדרש...לכאורה כל עוד לא הושגה הסכמה שכזו לא התקיים בתנאי	19
הראשון.	20
השאלה אם יש מקום לבחון את נימוקי ההתנגדות או שנאמר כי אלו אינם רלוונטים	21
ואם בכוחם להפוך התנגדות להסכמה".	22
ובהמשך-	23
"מכל מקום דומה כי אין אנו נצרכים להכרעה בין שתי הגישות במקרה דנן. כאמור,	24
טענת חוסר תום לב נטענה על ידי המשיבים בשני מישורים. המישור האחד, עניינו	25
בחינת ההתנגדות וסבירותה, נושא שהתייחסנו לעיל.	26
המישור השני, עניינו בסעד המבוקש על ידי המערער, דהיינו צו מניעה...התנגדותו של	27
המערער הינה בבחינת "טובל ושרץ בידו". דהיינו, המעשה הבלתי חוקי, לכאורה,	28
והחשש מפני נזקים כלכליים שיגרמו לאותו שימוש בלתי חוקי לכאורה, הם אלו	29
המניעים את המערער לפנות לביהמ"ש לסעד של צו המניעה.	30
...נבחן את מאזן הנוחיות נגיע לתוצאה דומה. מהעדויות שהובאו בפני המפקחת עולה	31
כי לכאורה מצבם של לפחות חלק מהמבקשים להתקין את המעלית, מצדיק גם מצדיק	32
את התקנתה. למעשה מדובר בהכרח להתקנתה אשר אלמלא כן יכול ויגרם למי	33
מהמשיבים להחלפת המגורים. וראו המפורט לעיל אודות הנסיבות המיוחדות של חלק	34
מהמשיבים דנן.	35

1 מנגד, אם נתעלם מהשימוש שלא כדין של המערער ביחידות המשרד, ולאור כל אשר
2 פורט לעיל, בחינת מאזן הנוחיות לא מראה על כל נזק שיגרם למערער...הנה כי כן,
3 העולה מהמקובץ עד כה כי דין הערעור להדחות וכי אין מקום להעניק למערער
4 בנסיבות הענין והמקרה, את הסעד לו הוא עותר".

5
6 פסק הדין עבר תחת שבט ביקרתו של ביהמ"ש העליון ברע"א (עלי) 7911/10
7 עו"ד יהודה רסלר נ' חנה תירוש, פורסם בנבו, שם נדחתה בקשת רשות הערעור
8 ונקבע, כי-

9 "בית משפט קמא עמד בפסק דינו על הרוב הדרוש להתקנת מעלית, באופן
10 המתיישב עם הוראות החוק. ברם, נפסק כי בתשתית העובדתית, שהוכחה
11 כאן, המבקש אינו זכאי לקבלת סעד מן היושר. ניתן משקל לעובדה כי קיימת
12 אי חוקיות בולטת ביחס לקניינו של המבקש...המבקש כלל לא טרח להתייחס
13 בבקשתו לתשתית העובדתית האמורה שנקבעה על ידי בית משפט ואכן צדק
14 בית משפט קמא משקבע שיש להעניק לה משקל במסגרת ההכרעה".

15 16 ב. מן הכלל אל הפרט:

17 לגופו של עניין, כשם כן כאן –מחד גיסא גם בפני אין בידי הנתבעים הסכמת בעל
18 דירה נוסף בבית שתשלים את מלוא מניין הסכמות הנדרשות להרחבת דירה
19 בבית משותף. ובהקשר זה, אף שאכן חלק מן הבניה מכוונת לאיטום חללים
20 קיימים אין לי ספק כי תוספת השטח למלוא הקונטור הקיים מהווה הרחבת
21 דירה במובנו של החוק.
22 מאידך גיסא כשם כן כאן- בפני בקשה למתן צו מניעה קבוע, סעד מן היושר,
23 המחייב להיזקק לבחינת טענות הנתבעים אשר להתנהלות התובעים.

24
25 הנתבעים התמודדו עם המכשול האריתמטי שהונח לפתחם בטענות שנדמה שאין
26 להקל בהם ראש. ראשית טענו, כי בשל טיבו של הסעד הנתבע יש להיזקק למניעי
27 התובעים שבלשונם בחרו "לנהל" מסע צלב" כנגד הנתבעים, המונע מצרות עין
28 גרידא". בהקשר למועד הגשת התובענה טענו הנתבעים לשיהוי היוצר מניעות
29 שכן נקבע עפ"י ס"ק ב' לסעיף 71ג' היה עליהם להגיש התביעה תוך 30 ימים
30 מיום קבלת ההחלטה או מיום המצאתה. התובענה לטענתם הוגשה מספר
31 חודשים מעת שהתקבלה ההחלטה בוועדת הערר בדיון בהתנגדותם שלהם.
32 בידיהם, נטען, 20 חתימות של דיירים על גבי הבקשה להיתר הבניה מתוך 28
33 דיירים בבניין. בנוסף טענו בסכומיהם, כי 4 דיירי הקומה האחרונה, "המודעים
34 היטב לתכנית ההרחבה ואף קיבלו את העתק הבקשה להיתר בהתאם לתקנה
35 ג2(ב) לתקנות הבקשה להיתר, לא הביעו כל התנגדות לתכנית" ואף לפי עדותו

של מר ליברמן תובע 3 בעמ' 8 ש' 31-32, בישרו לתובעים כי אין להם כל התנגדות	1
לתכנית אף שאינם מעוניינים מסיבותיהם לחתום עליה.	2
לטענתם התובעים ובעלי דירות הגג שהרחיבו דירותיהם בחדרי הגג מוחזקים	3
כמסכימים לבניה שבנדון. כמו כן העלו סברה, כי אטימת החללים אינה מחייבת	4
קבלת הסכמות אלא של בעל ה"חלל" ובעל הדירה שמתחתיו. פרק נרחב	5
בסכומיהם הקדישו לטענה כי יש ליתן משקל משמעותי לתום ליבם של התובעים	6
ולטעמי ההתנגדות זאת בהתאם לפסיקת בית המשפט המחוזי שאוזכרה על ידם.	7
	8
מנגד טען כאמור ב"כ התובעים, כי פסיקת בית משפט המחוזי אינה מסמיכה את	9
המפקחת לבדוק את נימוקי ההתנגדות, למעט בדיקה האם הנימוק נעוץ	10
במניעים פסולים כגון התנגדות הנובעת מקנטרנות, הפליה דתית וכיוצא בזה.	11
לדבריו "גם אם נאמץ את עמדות השופטים בפסיקה אשר סברו כי יש להרחיב	12
את סמכות הבדיקה של מניעי המתנגדים להרחבה ולבחון אותם במבחני תום	13
לב, לא יימצא כל דופי וכל רבב במניעי התובעים. התנגדותם של התובעים	14
מתאפיינת בהחלט בתום לב, יושר והגינות".	15
	16
לצד ההפניה ללשון החוק בדרישת הרוב יש להיזקק ללשון החוק להגשת תביעה	17
למפקח עפ"י סעיף 71ג' לחוק, אשר כאמור אינה אוטומטית. לא בכדי נחקק	18
סעיף נפרד (שלא במסגרת התנאים הקבועים בסעיף 71ב') ובו נקבעו תנאים	19
המחייבים את המתנגד דווקא (להבדיל מהחייבים החלים על הרוב לפי סעיף	20
71ב').	21
במקרה דנן חלה על המתנגד החובה לטעון ולהוכיח ממילא פגיעה מהותית	22
בזכויותיו. במקרה שבפני אף שלא עוולו התובעים ברם גם טענה לפגיעה מהותית	23
בזכויותיהם. טענה שכזו לא הוכחה ובגילוי לב, שבו וטענו כי אף הם חפצים	24
להרחיב את מרפסות דירותיהם בהזדמנות שנקרתה בדרכם ומכאן פגיעתם.	25
	26
ג. <u>בחינת סבירותה של ההתנגדות-</u>	27
"הכלל האומר כי "הבא לבקש יושר צריך לבוא בידיים נקיות" אינו מביע רעיון	28
מופשט המופעל באופן עיוור וללא אבחנה על-ידי בית-משפט-של-יושר. כמו	29
כל עיקרון משפטי אחר, הריהו צמוד לקרקע מוצקה של עובדות ומציאות,	30
המופעל בכל מקרה הלכה למעשה לפי נסיבותיו המיוחדות, לפי כל נסיבותיו	31
של המקרה. כאשר התובע בא לבית-המשפט בידיים לא נקיות והנתבע נפל	32
קורבן לתובע יימנע בית-המשפט מלהושיט יד-עזר לתובע על חשבון הנתבע,	33
וזאת כדי להציל עשוק מידי עושקו." (כב' השופט ברנזון בד"נ 12/60, כורי נ'	34
כורי, פ"ד י"ד(3) 2207, 2210)	35

ובע"א 17/62 לטוביציקי נ' לפלר, פ"ד יז (1) 87, 98 - "מתן צו המניעה הוא תמיד	1
ענין לשקול דעתו של בית המשפט, ולצורך זה מותר לו להביא בחשבון גורמים	2
שונים, נוסף על מידת הנזק הצפוי, כגון מידת הפגיעה בנתבע, אם הצו יינתן,	3
ובהתנהגות הצדדים."	4
	5
ממש כאותו מקרה המוצע ע"י כב' השופטת וסרקרוג, בעניין נטלה, ואף	6
כנסיבותיו של מר רסלר בפסה"ד של כב' השופט שנלר מתנגדים התובעים	7
להרחבה ויוצרים ביחד עם בעלי הזכויות בקומה השביעית מעליהם "גוש	8
חוסם", התנגדות מוצהרת לכאורה של התובעים והתנגדות פסיבית מצידם של	9
בעלי דירות הגג בקומה השביעית כלומר כלל בעלי הדירות העליונות-בעלות	10
מרפסות מורחבות מקדמת דנא- שמנועות תכנונית מלהתרחב. "גוש חוסם"	11
שבילתו לא יושג הרוב הנדרש.	12
אני סבורה כי יש בהתנגדות זו, בלשון כב' השופטת וסרקרוג, משום "ההתנגדות	13
של הרוב "המאורגן".. ואשר אין להם דבר או חצי דבר, עם הפגיעה בזכות	14
הקניינית לכשעצמה".	15
	16
תוצאתה של התנגדות בעלמא שכזו הובעה ע"י כב' השופטת וסרקרוג בע"א (חי')	17
2821/01 מרק וילסקר נ' ולדימיר לויט, פורסם בנבו-	18
"אם מוסכם עלינו, למשל, כי עקרון תום הלב חולש על כל החקיקה האזרחית וגם על	19
חוק המקרקעין, ואם נסכים כי עקרון תום הלב הוא חלק ממערך החקיקה בכלל, גם של	20
חקיקת היסוד, הרי שממילא בעצם הגדרת זכות הקניין, כמו הגדרת זכויות יסוד	21
אחרות, לא ניתן לדבר על זכותו של אדם לעשות בקניינו כברצונו, תוך התעלמות מיסוד	22
הסבירות וההגינות, אלא אם מימושה של הזכות נעשה תוך יישום עקרון תום הלב. גישה	23
זו ניתן לה ביטוי במאמרו של ד"ר חנוך דגן, "פרשנות בדיני קניין, הבית המשותף ובעיית	24
הפעולה המשותפת" (עיוני משפט כ (תשנ"ו) 45. התייחסות לנושא זה, ראה גם בע"א	25
1688/00 נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' בלהה (בילי) ברוך ואח', תק-מח 2001 (2)	26
(25884).	27
בין אם נבחר את הדרך הפרשנית הרואה את זכות הקניין, כזכות הקלאסית, ובין אם	28
נבחר בגישה הפרשנית המצמצמת יותר, מטרת תיקון מס' 18 לחוק המקרקעין, היא	29
להבהיר, שמקסום זכות הקניין של השותפים בנכס, יכול שתעשה לא על בסיס תחרות	30
לפיה שלי - שלי, גם אם לאחר לא נותר - במידה רבה העיקרון של "כופין על מידת	31
סדום" - אלא על בסיס שיתוף על-פי העיקרון של "זה נהנה וזה לא חסר".	32
בבסיס גישה זו ניתן לעשות שימוש בתורת המשחקים המדברת על מצבים בהם התמורה	33
שמניבה כל דרך פעולה הפתוחה בפני שחקן, תלויה בדרך הפעולה שבחר בה כל אחד	34
מהשחקנים האחרים. בין אם בחר השחקן הראשון לשתף פעולה עם בן זוגו, ובין אם	35

1	בחר שלא, התשלום שיקבל יהיה גבוה יותר, אם השחקן השני יחליט לשתף אתו פעולה,
2	מפני ששיתוף פעולה הדדי, יניב תמורה גדולה יותר עבור שניהם (י' מילכטייך, <u>משחקים</u> ,
3	מתוך גלילאו, גיליון 8, 1995. ראה גם ספרו של א' ברן <u>משחקיהם של בני אדם</u>) - עיקרון
4	לפיו ניתן למקסם את מימוש זכות הקניין על משאב אחד שהוא הבית המשותף, בדרך
5	של שיתוף בין הבעלים של אותו בית, ומבלי שהאחד ישיג על זכותו של האחר וישתלט על
6	רכושו של האחר. כך שאם קיימת פגיעה באחר, אין הכרח שתישלל זכותו המוחלטת של
7	הראשון, במקום שניתן לצמצם את פגיעתו של האחר, בדרך של מתן פיצוי למשל. זה
8	האיזון הנכון של זכות הקניין, כאשר השיתוף נמצא בבסיס יחסי השיתוף, ותוך ראייה
9	נכונה של אופן ניצול מקסימאלי של משאב המקרקעין.
10	בנסיבות אלה, כאשר מקסום הזכות מתאפשר מבחינת תכנון ובנייה, יש לאפשר את
11	הרחבת הדירות, תוך שמירה מאוזנת כי זכות כזו תשמר לכל אחד מבעלי הדירות ותוך
12	שמירה על עקרון השוויון. עיקרון זה, אין פירושו בהכרח, שכולם מקבלים תמורה זהה,
13	אלא שמידתיות התמורה תעשה לאורו של עיקרון השוויון. ראוי, כי נחנך ונתחנך
14	למדיניות של מימוש עצמי לזכות קיימת, תוך שמירה גם על זכותו של האחר, למימוש
15	מקביל של זכותו שלו, הכל תוך שמירה על מידתיות ראויה, באופן שפגיעה אם הייתה,
16	ויכול שתהיה, אינה במידה העולה על הנדרש.
17	יש בהוראה של תיקון החוק האמור, גם להצביע על היקפה ומהותה של הזכות הקניינית,
18	שיתכן שמלכתחילה איננה בבחינת כל יכול, ומתן הנחיה לבעל הזכות, כי מימושה של
19	זכות הקניין צריך שיעשה בסבירות, בתום לב, ותוך התחשבות באחר."
20	
21	התנגדות שאינה מצביעה, איפוא, על פגיעה כלשהיא בוודאי מהותית ואשר אין בצידה
22	פתרון תיכנוני אינה אלא התנגדות בעלמא, שאליה מכוונת כפי הנראה הפסיקה המנחה
23	את המפקח לבחון את תוכנה.
24	
25	ד. תום לב-
26	ישאל השואל האם יש בהתנהגות זו משום העדר תום לב. לטעמי, בנסיבותיו של המקרה
27	ולאור התוצאה המבוקשת שתהא אכן "לא לי אף לא לכם" יש משום פעולה שלא בתום
28	לב. בין היתר נטען, כי התובעים המציאו לידי הנתבעים "הסכמה" בדמות המכתב.
29	
30	המכתב-
31	כנספח ו' לתצהירו של עד הנתבעים מר צבי ליברמן צורף המכתב חתום ע"י "דיירי קומה
32	6 נריה 3 פ"ת" לפיו כאמור לאור החלטת הוועדה המחוזית "לא נותר אלא לאחל
33	למרחיבי המרפסת הנאה מהתוספות שיתווספו (ושלנו לא ניתנו)...אנו מבקשים לממש
34	את סעיף 71 ב' סעיף קטן ד' לתשלומי איזון".
35	בהקשרו של המכתב השיב בחקירתו תובע מס' 3 מר פופובסקי העד היחיד מטעמם של

1	התובעים, לאמור :
2	" ש. בחודש אוגוסט אתה שולח מכתב
3	ת. אני שלחתי?
4	ש. אתה יודע מי שלח
5	ת. אחד התובעים
6	ש. מדוע מי ששלח לא הגיש תביעה את אותה תביעה שאנחנו דנים בה עכשיו תוך זמן
7	קצר לאחר החלטת ועדת ערר
8	ת. אנשים ידעו שנערער על זה אנחנו דנים על ענין קנייני אני לא מבין את השאלות
9	האלה.
10	ש. בחודש אוגוסט הדיירים מקבלים מכתב שאתם מאחלים להם הנאה מהמרפסות כמו
11	כן ביקשתם ערבות ביצוע ותשלומי איזון למה את התביעה הזאת לא הגשתם
12	ת. פחדנו בציניות שאם נגיד שאם נגיש תביעה אתם תתבעו אותנו ...
13	ש. זה נכון שבהליך זה אתה אמרת שאם תכנונית הדבר לא יהיה אפשרי תרד מהתביעה
14	ת. כן וישלמו לנו דמי איזון
15	ש. לגבי תשלומי איזון אנחנו נתווכח עקרונית אם אין אפשרות תכנונית אתה מוותר
16	ת. אני לא חותם אבל בגדול לא היתה לי התנגדות, אם מלכתחילה לא הייתי יכול לבנות
17	לא הייתי מתנגד שמעתי שאפשרי וועדת ערר אמרה שאפשרי
18	ש. למה לא הבאת חוות דעת של איש מקצוע
19	ת. לא היו מסכימים שרה אמרה לי בצורה הכי ברורה שפרלמוטר לא מוכן לצאת מטר
20	משם ניסיתי לשכנע אותו הוא לא הסכים אני אישית הייתי אומר שתבנו" (ר' עמ' 5
21	לפרוטוקול הדיון מיום 17.7.11).
22	
23	וכן-
24	"ש. לך יש 6 מטר אתה מבקש ממנו להשקיע עשרות אלפי שקלים שיהיה לו 2 מטר סוכה
25	ונראה לך סביר
26	ת. למה מגיע לו 15 מטר ולי 6 מטר
27	ש. אתה מדבר על זה נהנה ולזה לא חסר
28	ת. אם הוא היה עושה מאמץ גם לי היה
29	ש. כמה זה היה עולה
30	ת. לא בדקנו".
31	
32	התובעים- כמי ששלחו את המכתב, אף לפי עדותו של תובע 3, לא הכחישו קיומו של
33	המסמך ואף לא תוכנו. יש ליתן, איפוא, אף למעין הסכמה זו משקל מסוים בנסיבות
34	המקרה ולכל הפחות לראות בה ראשית ראייה ל"זכות" שמבקשים התובעים הגנה בגינה
35	והיא דווקא הזכות לקבל פיצוי, בגין הבניה שלא יוכלו לקחת בה חלק, בדמות תשלומי

איזון.	1
	2
<u>מאזן הנוחות-</u>	3
אף במאזן הנוחות אני סבורה, כי אין הצדקה למנוע את ההרחבות המתוכננות	4
בבחינת "לא לנו ולא להם" אלא ליתן מזור לתובעים עפ"י החלופה המבוקשת על	5
ידם היינו בדמות בחינת זכאותם כאמור לתשלומי איזון.	6
	7
בשולי הדברים, בהקשרו של הטיעון "לא לי אף לא להם" נזקקתי למונח "כופין	8
על מידת סדום"- הסתייעתי בפסיקתו הרחבת של כב' השופט מנחם (מריו)	9
קליין, אשר קטונתי מהעמק בה, בתא(ת"א) 44809-10-11 רחל וגדני נ' סוזי	10
דויד, לא פורסם ובה קיבל ביהמ"ש בקשת מבקשים למתן צו מניעה זמני, מן	11
הטעם שהמשיבים עושים שימוש בזכויותיהם הקנייניות בדרך שאינה בתום לב	12
ובניגוד להוראת סעיף 14 לחוק המקרקעין ותוך הסתייעות בכלל המצוי בדן	13
העברי לפיו "כופין על מידת סדום".	14
בשל זיקתם של הצדדים שבפני לדין העברי ואף שאיני מייחסת להם חלילה	15
מידת סדום, סברתי כי יתכן ויצאו נשכרים מציטוט נרחב מפסק הדין שבו הובא	16
"מאמרו של ד"ר אברהם וינרוטו "שימוש לרעה בזכות במשפט העברי ("כופין על	17
מידת סדום"), דיני ישראל, כרך יח (תשנ"ה-תשנ"ו), עמ' סט), ציין:	18
"לפי הראבי"ה נמצא, כי כופים על אדם לאפשר לרעהו להיכנס לשדה ריקה שלו ,	19
שאינה מושכרת ואינה עומדת להשכרה, שכן בהעדר הצדקה כלכלית למניעת הנאה מן	20
הזולת, מהווה העמידה של הבעלים על זכויותיו, שימוש לרעה בהן, וכופין על מידת	21
סדום. הרי לך הגבלה ברורה ביותר על השימוש של אדם פרטי בזכות הקניין שלו,	22
והכפפת זכות הקניין לנורמות של סבירות. בהתאם לנורמה זו, בעלותו של אדם לעולם	23
אינה מוחלטת והיא כפופה לחובותיו של הפרט כלפי התורה, ומשום כך סירוב בלתי	24
סביר לאפשר לזולת להנות מקרקע כאמור, אינו אפשרי על פי דין".	25
---	26
הפיתרון של קביעת תשלומי איזון (שתבחן על ידי להלן ט.ל), כאשר מרחף מעל הסכסוך	27
הכלל של "כופין על מידת סדום" אומץ להלכה בתשובתו של מהר"ם מרוטנבורג, 1293-	28
1215, מגדולי בעלי התוספות וחכמי אשכנז בדורו (שו"ת בעלי התוספות, סימן ע:)	29
"ראובן שהיה לו בית, ומכר חציו לשמעון. שוב מכר חציו השני ללוי ויהודה, לכל אחד	30
רביע. כי מטו למיפלג [כאשר באים להתחלק] לא מצו לוי ויהודה לומר לשמעון: 'הואיל	31
ולדידן ליכא לכל חד וחד אלא רביע, ליפלוג לארבעה חלקים, ושקול אתה תרי מנתי	32
דידך במקום שיפול לך הגורל, או זה אצל זה או מופלגין זה מזה, ואנן נשקול נמי כל חד	33
וחד מנתא ידידיה, כאשר יפול הגורל'. משום דאמר להו: 'לא עדיפיתו מגברא דאתיתי	34
מיניה [בבא מציעא, דף קא, עמ' ב], דראובן גופיה בעידנא דזבן לא היה יכול להכריחו	35

1	ליקח חלק בשתי מקומות. אלא אי הוה בעינא למיפלג כל כמה דהוה קרקע דיזכו ביד
2	ראובן היינו חולקין כל הבית לשני חלקים ותו לא. דלא גרע מתרי ארעתא אחד נגרא
3	דאמרינן [בבא בתרא, דף יב, עמ' ב] כגון זה כופין על מדת סדום, אע"ג דאי אפשר
4	לצמצם שיהו שתיהן שוות לגמרי. ואפילו אם אחת שווה לימכר יותר מחבירתה, זה
5	יעלו בקרקע או בכספים. כל שכן בנדון זה, שהכל בית אחד שלא יחלקוהו אלא לשני
6	חלקים, אפילו אם מצד אחד בניין עליות וחדרים יותר מצד השני, זה יעלו גם בכספים
7	שנותן לו, או יעלוהו בקרקע שיטול באורך וברוחב יותר מן השני בשווה, זה נוטל
8	במקום שיש חדרים ועליות עשר אמות, יטול השני במקום שאין בניינים עשרים אמות,
9	הכל כמו שיעריכוהו בני אדם הבקיאים בשומא שיהא שוה. ואז יפילו גורלות. "
10	וכך פוסק הרמב"ם להלכה בהלכות שכנים, פרק יב, הלכה א :
11	" האחין או השותפין שבאו לחלוק את השדה וליטול כל אחד חלקו, אם היתה כולה
12	שווה ואין שם מקום טוב ומקום רע, אלא הכל אחד - חולקין לפי המידה בלבד. ואם
13	אמר אחד מהם: 'תנו לי חלקי מצד זה כדי שיהא סמוך לשדה אחר שלי, ויהיה הכל
14	שדה אחת' - שומעין לו, וכופה אותו על זה, שעיכוב בדבר זה, מידת סדום היא. אבל
15	אם היה חלק אחד ממנה טוב או קרוב לנהר יותר או קרוב לדרך, ושמו אותה היפה כנגד
16	הרע, ואמר: 'תנו לי בשומא שלי מצד זה' - אין שומעין לו, אלא נוטל בגורל. אמר להם:
17	'תנו לי בשומא שלי מצד זה חצי מידתה מן הצד הרע בלא שומא, וטול אתה מן הצד
18	הטוב, כדי שיהיה חלקי סמוך לשדה שלי - 'הורו מקצת הגאונים ששומעין לו. ולזה
19	דעתי נוטה, וכן ראוי לדון."
20	בשולחן ערוך וברמ"א, מובאת ההלכה כך (חושן משפט, סימן קעד, סעיף א) :
21	" האחין או השותפין שבאו לחלוק השדה וליטול כל אחד חלקו, אם היתה כולה שווה
22	לגמרי - חולקין לפי המידה בלבד. ואם אמר אחד: 'תנו לי חלקי מצד זה, כדי שיהא
23	סמוך לשדה אחר שלי, ויהיה הכל שדה אחד' - שומעין לו, וכופה אותו על זה, שעיכוב
24	בדבר זה מדת סדום היא) ויש אומרים) דאין שומעין לו, אלא צריך להעלות בדמים עד
25	שיתרצו חביריו) (טור בשם הרא"ש). ויש אומרים: דהוי ספק, וכל דאלים גבר (מרדכי
26	סוף פ' קמא דב"ב בשם מהר"ם. (אבל אם היה חלק ממנה טוב, או קרוב לנהר יותר, או
27	קרוב לדרך, ושמו אותה היפה כנגד הרע, ואמר: 'תנו לי בשומא שלי מצד זה - 'אין
28	שומעין לו, אלא נוטל בגורל. אמר להם: 'תנו בשומא שלי מצד זה חצי מידתה מהצד
29	הרע, וטול אתה מהצד הטוב, כדי שיהא חלקי סמוך לשדה שלי' - שומעין לו. הגה: היו
30	בכאן שני שדות, האחד אומר לחלוק כל שדה ושדה, והאחד אומר לחלוק שדה כנגד
31	שדה - שומעין לזה שאומר לחלוק שדה כנגד שדה; ודווקא ששתיהן שוות, ואין
32	נפקותא בחלוקת השדות לחצאין. אבל אם האחד טובה בשום צד, או שאחד יש לו מצר
33	אצל השדות - חולקין כל שדה לשנים (טור ס"ג)." .
34	המהרי"ק (ר' יוסף בן שלמה קולון, 1480 - 1420, מגדולי חכמי איטליה) בשו"ת

1 המהרי"ק, סימן ט, ד"ה, מבהיר שהעיקרון של "זה נהנה וזה לא חסר" איננו מתייחס רק
2 למצב של העדר חסרון כלל, אלא גם אם יש חיסרון מועט אנו מאזנים את החיסרון הזה
3 מול התועלת שיש לצד השני, ולכן במאזן הכולל, המסקנה היא כי יש להפעיל את
4 העיקרון של "כופין על מידת סדום".

5 בהקשר של פגיעה בזכויות קנייניות, איזכר כב' השופט קליין את הרמב"ם הקושר את
6 הפטור של "זה נהנה וזה לא חסר" עם הכלל של "כופין על מידת סדום" וכך נפסק
7 בהלכות שכנים, פרק ז, הלכה ח: בשולחן ערוך, חושן משפט, סימן קנד, סעיף ג, מובא על
8 ידי הרמ"א, ובהרמב"ם, בהלכות שכנים, פרק ח, הלכה ד.

9 10 ה. טענת השיהוי-

11 חזרה לבחינת נסיבותיו של המקרה תוך היוזקות לטענת השיהוי שנטענה.
12 הנתבעים טענו כי השיהוי בהגשת התובענה נעשה תוך פגיעה בציפייה לגיטימית של
13 הנתבעים, בפרט לאור ההסכמה המפורשת שהובעה במכתב.
14 בהקשר זה, נקבע בין היתר, בע"א 8630/05 **ניר שיתופי אגודה ארצית להתיישבות עובדי**
15 **נ' עיריית הוד השרון**: "שיהוי בהגשת תביעה נוצר מקום בו יש בהשתהות בפנייה לבית
16 המשפט משום שימוש לא נאות בזכות התביעה הנתונה לתובע ופגיעה בציפייה הלגיטימית
17 של הנתבע שלא להיתבע. לפיכך, בכדי שייקבע כי תביעה הוגשה בשיהוי על הנתבע להוכיח
18 כי בנסיבות המקרה התובע זנח את זכות התביעה; או כי במשך הזמן שינה הנתבע את
19 מצבו לרעה; או כי השיהוי נגרם עקב חוסר תום לב מצד התובע". (ראו, ע"א 6805/99
20 **תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון**
21 **ולבניה ירושלים**, פ"ד נז(5) 433 (להלן - פרשת תלמוד תורה); ע"א 410/87 **עזבון ליברמן נ'**
22 **יונגר**, פ"ד מה(3) 749, 756-755; ע"א 403/63 **תמיר נ' שמאלי** פ"ד יח(1) 47, 53-54).
23 יש פנים, איפוא, לטענת הנתבעים, אם כי לא בשל טענת השיהוי דינה של התובענה שבפני
24 להדחות.

25
26 ו. עולה מן האמור שהתנגדותם של התובעים שאינה מבוססת על כל טענה לפגיעה מהותית,
27 בהעדר תוכנית אופרטיבית להכללתם בהרחבת המרפסות ותוך דרישתם לכפות תוכנית
28 ערטילאית שכזו – הגם שתפגע בסוכות שכניהם- אינה מזכה לטעמי בסעד מן היושר
29 בדמות מתן צו מניעה קבוע לכל הרחבה מחוץ לדירות התובעים כנתבע על ידם.
30 בהקשר זה אף ששקול דעתו של ביהמ"ש במקרים כגון דא מצומצם, ובשים לב לכך
31 שבמקרה דנן, לא הוכח כי אכן מדובר בזכות קניין שיש להיזקק להגנה דווקאנית עליה
32 (רי' ע"א 538/80 **סמדר דרחי (אברהמי) נ' יהודה כורש ואח'** פ"ד לו(3), 498) ופסק הדין
33 בעניין רוקר).

34 אני סבורה כי אין להותיר את הנתבעים תלויים בהסכמה (המכתב) ובחזרה ממנה של

1 מי מ"הגוש החוסס" וכי עקרון תום הלב החל כאמור גם על התובעים מחייב בחינת מתן
2 הסעד כספי דווקא, כמבוקשם "בהסכמה" שהובעה על ידם במכתב.

3
4 **7. תביעה חלופית למינוי מומחה ופסיקת תשלומי איזון:**

5
6 סעיפי החוק הרלוונטיים בהקשר זה הם-

7 סעיף 71ג. לחוק המקרקעין-

8 **"(א) בעל דירה המתנגד להחלטה שנתקבלה כאמור בסעיף 71ב(א), וטוען לפגיעה מהותית**
9 **בזכויותיו, בעל דירה המבקש מינוי שמאי מקרקעין בהעדר הסכמה, או בעל דירה החולק על**
10 **קביעת השמאי רשאי לפנות למפקח בתביעה.**

11 **(ב) התביעה תוגש תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה, ואם בעל הדירה לא היה נוכח בעת**
12 **קבלת ההחלטה, תוך 30 ימים מיום המצאת ההחלטה; המפקח רשאי להאריך את המועד**
13 **להגשת התביעה מטעמים מיוחדים שיירשמו."**

14
15 בסעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין, נקבע-

16 **"נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור**
17 **יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה,**
18 **תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי**
19 **ברכוש המשותף."**

20
21 **א. ראשית הזכאות לתשלומי איזון קורמת עור וגידים רק במקום שבו בעל דירה, שדירתו**
22 **ניתנת להרחבה מנצל שיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף לשם אותה הרחבה.**
23 בפני אין אף ראשית ראיה לניצול בשיעור כלשהו של אחוזי הבניה בכלל או ביחס
24 לחלקים ברכוש המשותף בפרט. משהוגשה התובענה ולאור הוראת סעיף 71ג' הנטל רובץ
25 לפתחם של התובעים. יוצא, איפוא, שאין לדעת אם במקרה זה התעורר צורך בתשלומי
26 איזון שכאלו, ומאחר ודברים אלו לא הוכחו, ואף לא נטענו, לא הונחה תשתית מספיקה
27 למתן הצו ההצהרתי המבוקש.

28
29 **ב. זאת ועוד, המועד כאמור להגשת תובענה לתשלומי איזון הינו בתוך 30 ימים**
30 **מיום קבלת ההחלטה או מיום המצאת ההחלטה. התובעים התעלמו מן הנתען**
31 **בהקשר זה וטענתם היא שהמועדים המנויים בסעיף אינם מחייבים עמידה**
32 **מפורשת בהם.**

1	ג. בפני, איפוא, לשון החוק המחייבת הגשת תובענה בפרק זמן מסוים והסיפא לו הקובעת,
2	כי "המפקח רשאי להאריך את המועד להגשת התביעה מטעמים מיוחדים שיירשמו".
3	אנסה כוחי, איפוא, באותם טעמים מיוחדים שירשמו שכן זו לטעמי התוצאה הראויה
4	בנסיבות המקרה (ואף ברוח סעיף 75(א) לחוק המקרקעין).
5	
6	ד. <u>טעמים מיוחדים שירשמו-</u>
7	החלופה המבוקשת הינה חלק ממאזן הנוחות לדחיית הסעדים שביושר בנסיבות
8	המקרה, ומהווה אף פתרון ראוי בשים לב לכך ששוכנעתי שדירת התובעים לא ניתנת
9	עובדתית להרחבה-כלשונו המפורשת של הוראת סעיף 71(ד)- המכוונת למתן תשלומי
10	איזון בנסיבות אלה.
11	זאת ועוד, אף לא ברור לפי שעה האם כלל נוצלו ביתר אחוזי הבניה והאם מתקיים
12	התנאי בלתו אין תשלומי איזון. נתון עלום זה מהווה איזון ראוי בין עמדת התובעים לזו
13	של הנתבעים. הנטל בהקשר זה לא הורם ע"י הנתבעים בשים לב להוראת סעיף 71ב'
14	ואף לא ע"י התובעים לפי ס' 71ג'.
15	למעלה מן הצורך, מצאתי כי יש בחלופה זו אף מזור לטענות התובעים ולהמיית ליבם
16	עפ"י המכתב.
17	אני סבורה איפוא כי בנסיבות המקרה יש טעם מיוחד למתן אורכה לתובעים להגשת
18	תובענה מתאימה, לאחר שאלה יבססו את התשתית הראייתית לכך שאכן הנתבעים ניצלו
19	ביתר אחוזי בניה כאמור בסעיף 71ב'.
20	ודוק. אמנם, הסעד למתן תשלומי איזון נתבע לכאורה בתובענה שבפני ולא הוכח
21	כמתחייב אף בראשית ראיה ואולם, לאור הנטל ההדדי המתואר החל הן על התובעים
22	והן על הנתבעים ואף לאור הוראת סעיף 75(א) לפיה- "מפקח הדן בסכסוך רשאי לסטות
23	מדיני הראיות ומסדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט, אם היה משוכנע שהדבר יועיל
24	לגילוי האמת ולעשיית צדק; החליט לסטות מדיני הראיות ומסדרי הדין הנוהגים בבתי
25	המשפט, ירשום את הטעמים שהניעוהו לכך", שוכנעתי כאמור כי זו התוצאה הראויה
26	אף לשם "עשיית צדק" שלא לומר עשיית הדין גופא.
27	ניתנת, איפוא, אורכה של 90 ימים נוספים להגשת תובענה כאמור.
28	
29	
30	8. נותר לבחון את דרישת התובעים לחייב הנתבעים בהפקדת ערובה שתבטיח ביצוע הבניה בהתאם
31	להיתר הבניה, תוך הימנעות מגרימת נזק לרכוש משותף. מדובר בסעדים שאינם מצויים
32	בסמכותי העניינית המנויים בפרק ו' לחוק המקרקעין ולפיכך אינני נדרשת להם.
33	
34	

9.	ומכאן השאלה מי ישא בהוצאות ההליך דנן. מחד גיסא נדחתה מרבית התביעה, מאידך גיסא	1
	ההצעה שהוצעה ע"י התובעים לבחון האפשרות לתשלומי איזון, אף היא נדחתה ע"י הנתבעים-	2
	הגם שכל שנוצלו זכויות בניה ביתר (דבר שלא הוכח בשלב זה) היו הם מחויבים לפעול לשלם	3
	במועד ההרחבה תשלומי איזון לתובעים.	4
	כל צד התבצר, איפוא, בעמדתו והצדדים לא השכילו ממילא לבחון יחדיו את <u>תנאי הסף</u>	5
	<u>לתשלומי האיזון</u> , שיכול שהיה עפ"י טענת התובעים מייתר מצידם את הגשת התובענה דנן.	6
	אין איפוא מנוס אלא להטיל על כל צד לשאת בהוצאותיו שלו.	7
		8
	התוצאה היא כי מרבית התביעה נדחתה, פרט להארכת המועד להגשת התובענה לתשלומי	9
	האיזון, בתוך 90 ימים מיום קבלת פסק דין זה. אין צו להוצאות נוספות כאמור.	10
		11
	ניתן בלשכתי היום י"ז אייר תשע"ב, 09 מאי 2012, בהעדר הצדדים וישלח אליהם ע"י מזכירות	12
	הלשכה.	13
		14
		15
		16
		17
	טלי להב	18
	המפקחת על רישום המקרקעין	19
	פתח תקוה	20
		21